

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2011/11073

- Acusados: Alexandre Bride
José Martins Pereira
José Roberto Amorielo
Oriel Campos Leite
Paulo César de Moura Bueno
Regina Martin Ferrari
Reno Ferrari
Reno Ferrari Filho
- Ementa: Não divulgação, no Formulário de Referência, de informações relevantes acerca de contratos de mútuo. Advertência e Absoluções. Operação fraudulenta. Multas. Abuso do poder de controle. Multa e absoluções. Não apresentação de justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão de ações decorrentes de aumento de capital. Advertências. Suposto descumprimento do dever de diligência. Absoluções.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as arguições interpostas pela defesa de prescrição, tanto quinquenal quanto intercorrente.
 2. No mérito:
 - 2.1. Aplicar aos acusados **José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite** a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$500.000,00**, pela prática de operação fraudulenta, em infração ao disposto no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76;
 - 2.2. Aplicar ao acusado **Reno Ferrari Filho** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$157.817.125,00**, correspondente a 25% do valor da operação irregular de integralização de ações, em infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76;
 - 2.3. Aplicar aos acusados **José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite**, na qualidade de membros do conselho de administração da Clarion, a penalidade de **advertência**, por não terem justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão das ações decorrentes do aumento de capital da companhia deliberado em 30.12.2008, em infração ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76;
 - 2.4. Aplicar aos acusados **Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari**, na qualidade de membros do conselho de

administração da Clarion, a penalidade de **advertência**, por não terem justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão no aumento de capital da companhia deliberado em 28.6.2010, em violação ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76;

- 2.5. Aplicar ao acusado **José Roberto Amoriello** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$25.000,00**, por não ter justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão no aumento de capital deliberado em 28.6.2010, em violação ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76;
- 2.6. Aplicar ao acusado **Alexandre Bride**, na qualidade de diretor de relações com investidores, a penalidade de **advertência**, por deixar de prestar, no formulário de referência, informações relevantes acerca de contratos de mútuo, em infração ao disposto no art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009;
- 2.7. **Absolver Reno Ferrari** da imputação de infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, no tocante ao aumento de capital da Clarion S.A. ocorrido em 30.12.2008;
- 2.8. **Absolver Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno**, na qualidade de diretores da Clarion S.A., da imputação de violação ao disposto no art. 245 da Lei nº 6.404/76;
- 2.9. **Absolver Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho** da acusação de infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea f, da Lei nº 6.404/76; e
- 2.10. **Absolver Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno**, na qualidade de diretores da Clarion S.A. da imputação de descumprimento dos deveres de diligência e de desvio de poder, em suposta violação ao disposto nos artigos 153 e 154 da lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2011/11073

Acusados: José Martins Pereira
Oriel Campos Leite
José Roberto Amoriello
Paulo César de Moura Bueno
Alexandre Bride
Reno Ferrari
Reno Ferrari Filho
Regina Martin Ferrari

Assunto: Falta de comutatividade em operações entre partes relacionadas (art. 245 da Lei nº 6.404/76); abuso do poder de controle (artigos 116, parágrafo único, e 117, §1º, "f", da Lei nº 6.404/76); descumprimento do dever de diligência (art. 153 da Lei nº 6.404/76); desvio de poder (art. 154 da Lei nº 6.404/76); fraude ao procedimento previsto para realização de aumento de capital com bens (art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76); não apresentação de justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão de ações decorrentes de aumento de capital (art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76); não apresentação de informações requeridas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM nº 480/2009 (art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face de José Martins Pereira, Oriel Campos Leite, José Roberto Amoriello, Paulo César de Moura Bueno, Alexandre

Bride, Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho e Regina Martin Ferrari para apuração de suas responsabilidades quando (i) do aumento de capital da Clarion S.A. Agroindustrial ("Clarion" ou "Companhia")¹ realizado em 30.12.2008; (ii) da celebração de contrato de mútuo em 27.7.2006; (iii) do arrendamento de unidade industrial; e (iv) do aumento de capital da Companhia realizado em 28.6.2010, em suposta infração ao disposto nos artigos 116, parágrafo único, 117, §1º, "f", 153, 154, 156, 170, §§ 3º e 7º, e 245, todos da Lei nº 6.404/76, bem como ao disposto no art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009.

2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2009/1205, em que a SEP apreciou reclamações formuladas por investidores relativas à reunião do conselho de administração da Clarion realizada em 30.12.2008, na qual se aprovou: (i) a aquisição de ativos pertencentes à Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração (a então controladora da Clarion, a seguir referida como "Manacá") e à M.A., sociedade também controlada pela Manacá; (ii) os laudos de avaliação referentes a tais ativos; e (iii) o aumento de capital social da Companhia, realizado dentro do limite do capital autorizado.

II. FATOS

3. No âmbito da mencionada reunião do conselho de administração, ocorrida em 30.12.2008, os conselheiros da Clarion deliberaram a aquisição (i) de unidade produtora de álcool situada no município de Ibaiti, Paraná, que era de propriedade da Manacá, no valor de R\$ 452.350.000,00; e (ii) de lavouras de cana de açúcar, que eram de propriedade da M.A., no valor de R\$ 178.918.500,00.

4. Segundo a ata da reunião (fls. 06 a 08), os ativos foram avaliados pela sociedade E.M., que, conforme apurado pela SEP, tinha, como objeto social cadastrado no Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, "*atividades de gravação de som e de edição de música*".

5. Também consta dessa ata que a Manacá e a M.A. constituíram mútuos com a Clarion por meio dos quais essas sociedades passaram a deter, contra a Companhia, crédito no valor dos ativos que cada uma alienou, conforme discriminado no parágrafo terceiro acima. A esse respeito, mencione-se que tais mútuos foram constituídos com base em cláusulas integrantes dos contratos de compra e venda que continham a seguinte redação:

(i) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e Manacá, cláusula segunda, "A": "*O preço certo ajustado para a presente transação é o de R\$ 452.350.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil Reais), objeto de Contrato de Mútuo celebrado entre as partes, cujo instrumento faz parte integrante do presente contrato de Venda e Compra, com a cláusula pró-soluto*" (fl. 46).

(ii) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e M.A., cláusula 2.2: "*A Compradora pagará à vendedora, o valor atualizado na forma do item anterior, em parcela única no dia 30 de dezembro de 2008 mediante contrato de mútuo junto à Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração (Controladora da [M.A.]) cujo as partes reconhecem, para todos os fins de direito, como prova de recebimento e de quitação*" (fl. 51).

6. Também consta da ata que o contrato de mútuo celebrado em favor da M.A. fora cedido à Manacá e que a Manacá já possuía outro contrato de mútuo com a Clarion, em decorrência do qual a Companhia devia à Manacá R\$ 111.694.412,27². Sendo assim, o valor total dos contratos de mútuo celebrados em favor da acionista controladora consistia em R\$ 742.962.912,27, que, segundo a ata, seria utilizado exclusivamente para subscrever aumentos de capital da Companhia.

7. Ainda na mesma reunião, os conselheiros deliberaram o aumento do capital social da Clarion, dentro do limite autorizado, de R\$ 80.000.000,00 para R\$ 800.000.000,00³, tendo sido assegurado o direito de preferência aos antigos acionistas da Clarion. O preço de emissão das ações, de R\$ 26,42, foi estabelecido com base no valor patrimonial. Conforme consta da ata, a escolha do critério de precificação foi assim justificada:

"O preço de emissão das ações foi fixado com observância do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76 e parecer de orientação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de números 1/78 e 5/79, prevalecendo o critério do Valor Patrimonial das Ações, que, em 30.09.2008, é de R\$ 26,42, tendo em vista que apesar do registro de seus títulos para negociação em Bolsa, ainda não houve negociação. O objetivo da presente emissão é a ampliação das atividades da companhia, contemplando seu objeto social, com o reforço do capital de giro e a redução do endividamento da companhia" (fls. 07 e 08).

8. Como apurado pela SEP⁴, a composição acionária da Manacá era formada por Reno Ferrari, detentor de 0,5% das ações, e pela companhia estrangeira G.I.C., detentora dos restantes 99,5%. Todas as ações emitidas por esta sociedade, por sua vez, eram detidas por Reno Ferrari Filho⁵.

9. Em 3.2.2009, M.C.T., acionista da Clarion, protocolou reclamação na CVM na qual afirmou, principalmente, *"que se sente prejudicada, haja vista que não tomou conhecimento dos LAUDOS AVALIATÓRIOS"* (fl. 03). Também informou que, ao solicitar os respectivos documentos à administração da Companhia, o acusado José Martins Pereira, então diretor-presidente e presidente do conselho de administração da Clarion, teria lhe informado que tais documentos somente seriam disponibilizados após o vencimento do prazo de exercício do direito de preferência (o que ocorreria em 5.2.2009).

10. Alegou, por fim, que a Manacá, *"ao 'vender' os seus ativos à CLARION pelo preço que quis e ao transformá-lo em ações, está sendo privilegiada em detrimento da Requerente, que, para continuar com a participação atual que possui no capital da sociedade terá que integralizar, à vista, R\$ 19.229.189,34"* (fl. 06).

11. No dia seguinte, em 4.2.2009, R.S., outro acionista da Clarion, protocolou correspondência na CVM, informando, principalmente, que os documentos que embasaram as deliberações tomadas na reunião do conselho de administração não haviam sido franqueados aos acionistas, em infração, segundo ele, ao art. 170, §§ 3º e 7º, da Lei nº 6.404/76⁶, e tampouco foram disponibilizados por meio do Sistema de Informações Periódicas – IPE da CVM (fls. 15 e 16).

12. Esse acionista relatou ainda que apresentara protesto na assembleia geral ordinária e extraordinária de 30.4.2008 relativo à aprovação das contas dos administradores. De acordo com ele, as unidades industriais de propriedade da Manacá adquiridas pela Clarion, que foram objeto de fato relevante publicado em 25.7.2007, teriam sido utilizadas em detrimento dos interesses sociais da Companhia e em benefício de seus controladores.

13. Isso porque, segundo R.S., as justificativas para a aquisição desses ativos foram logo em seguida ignoradas pelos administradores da Clarion, que celebraram, em 1.9.2007, contrato de arrendamento com a “*empresa ligada*” P.A.C., por meio do qual arrendou as unidades por prazo indeterminado e a uma remuneração de R\$300.000,00 por mês. Como apurado pela SEP, esse valor consistia em uma remuneração equivalente a 0,51% do valor pago pelas unidades, de R\$58.261.000,00.

14. Conforme informado pela Clarion⁷, o quadro de quotistas da P.A.C. era composto pelos Senhores R.M.F., titular de 50% das quotas, e A.L.C.A., titular dos outros 50%. R.M.F., de acordo com a Companhia, é filho do acusado Reno Ferrari e irmão dos também acusados Reno Ferrari Filho e Regina Martin Ferrari.

15. Em resposta a questionamento da SEP datado de 5.2.2009⁸ (fls. 19-21), a Clarion afirmou, em síntese, que a aquisição dos ativos de propriedade da Manacá e da M.A. foi realizada pelos valores constantes dos laudos de avaliação e teria como objetivo ampliar as atividades da Companhia dentro do seu objeto social. Alegou também que a utilização dos contratos de mútuo no aumento de capital teria como fim capitalizar-se e fazer com que não houvesse a incidência de juros ou atualizações monetárias sobre tais contratos.

16. A Clarion também respondeu que os laudos de avaliação estavam à disposição dos acionistas em sua sede social, refutando a alegação dos reclamantes no sentido de que eles só teriam sido disponibilizados após o fim do prazo para exercício do direito de preferência. Ainda nessa resposta, informou que a ata da reunião do conselho de administração de 30.12.2008 e o fato relevante de mesma data relativo aos laudos de avaliação elaborados pela E.M. foram encaminhados à CVM e à Bovespa em 2.1.2009, tendo sido enviado também aviso aos acionistas em 6.1.2009, todos por meio do Sistema IPE. Assim, concluiu que tais documentos foram encaminhados dentro dos prazos legais.

17. A Companhia destacou que não houve infração ao art. 170, §§ 3º e 7º, da Lei nº 6.404/1976, uma vez que o aumento de capital não foi integralizado em bens. Esclareceu, nesse sentido, que houve a aquisição de ativos pela Clarion, tendo-se constituído a favor dos vendedores contratos de mútuo que foram efetivamente objeto de capitalização.

18. Em resposta à nova inquirição da SEP, datada de 9.3.2009⁹, a Clarion esclareceu que o valor patrimonial das ações foi fixado com base no dia 30.9.2008 e que, no seu entendimento, seria o critério mais justo diante da inexistência de cotações, “*já que o da avaliação pelo Valor de Avaliação Econômica (perspectivas de rentabilidade futura) se justificaria melhor no caso de aquisição ou venda de uma empresa, projeto ou unidade, na totalidade de suas cotas ou ações*” (fls. 35-192). Além disso, a Companhia fundamentou a escolha do valor patrimonial com base nos itens 4¹⁰ e 7¹¹ do Parecer de Orientação da CVM nº 1/78.

19. Em 28.6.2010, o conselho de administração da Clarion aprovou outro aumento de capital para R\$ 1.000.070.000,00, dentro do limite do novo capital autorizado¹², que, conforme estabelecido, poderia ser subscrito mediante espécie ou quaisquer créditos detidos contra a Clarion, tendo sido conferido prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência. Conforme se verificou posteriormente, os créditos efetivamente utilizados foram apenas aqueles decorrentes de contrato de mútuo celebrado entre a Companhia e a Manacá, sendo esta a única subscritora do aumento¹³. Participaram da reunião os conselheiros acusados Regina Martin Ferrari, Reno Ferrari e José Roberto Amorielo.

20. Nos termos da justificativa a seguir, constante de anexo à ata da reunião do conselho de administração, o preço de emissão das ações foi de R\$ 9,50:

"O critério utilizado para o cálculo do preço de emissão foi a média dos últimos 6 meses (04.01.10 a 10.06.10), no qual o preço encontrado foi de R\$10,46 para as ações preferenciais. Vale destacar que as ações ordinárias da companhia não foram cotadas até o presente momento. Cabe ressaltar que a companhia decidiu promover um deságio de 9,18% sobre a média dos últimos 6 meses para as ações preferenciais, o que nos fez chegar ao preço de R\$ 9,50. No caso das ações ordinárias (que não apresentaram até o presente momento nenhuma cotação), o preço estipulado terá como base o mesmo preço utilizado para as ações preferenciais. Importante salientar que o deságio proposto pela companhia tem como objetivo, exclusivamente, criar uma atratividade adicional para que os atuais acionistas subscrevam sua participação proporcional ao aumento de capital."

21. Atendendo a novo questionamento encaminhado pela SEP à Clarion em 16.6.2011¹⁴, os acusados José Martins Pereira, José Roberto Amorielo e Oriel Campos Leite, membros do conselho de administração da Clarion presentes à reunião de 30.12.2008, afirmaram que a nomeação da E.M. não foi objeto de deliberação em assembleia geral porque o aumento não se deu com a integralização de bens, mas com a integralização de créditos decorrentes de contrato de mútuo (fls. 273-275). Assim, não haveria a incidência do art. 170, §3º, conjugado com o art. 8º¹⁵, ambos da Lei nº 6.404/1976.

22. Os conselheiros também afirmaram que a E.M. exerce mais de uma atividade, mas, como o SERPRO só abarca a inclusão de uma delas, apenas aquela relativa à gravação de som e de edição de música constava do cadastro. Nesse sentido, reforçaram que os laudos foram assinados por profissionais devidamente habilitados para as avaliações.

23. Adicionalmente, sustentaram que "os valores atribuídos aos bens avaliados pelos laudos da [E.M.] não podem, em momento algum, ser considerados inadequados, tendo em vista que laudos posteriores sobre os mesmos bens, emitidos por outras empresas também especializadas, atribuíram valores semelhantes àqueles atribuídos pela primeira. Tal fato poderá ser comprovado pela simples análise dos laudos posteriores, caso seja de interesse desta Autarquia" (fl. 274).

24. Manifestando-se a respeito do protesto realizado por R.S., a Companhia alegou que o arrendamento por ele contestado ocorreu para suprir a falta de capital de giro

para explorar a unidade industrial, tendo sido a decisão que melhor atendeu aos interesses dos acionistas da Clarion.

25. Nos dias 14.10.2011 e 18.10.2011, a SEP enviou novas solicitações de manifestações individuais aos acusados Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho, Paulo César de Moura Bueno, Alexandre Bride e Regina Martin Ferrari¹⁶.

26. Sobre a aquisição da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007 e a posterior celebração, pela Companhia, de contrato de arrendamento de unidade industrial em 1.9.2007, Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho afirmaram, em síntese, que o principal objetivo da aquisição foi permitir uma atuação integrada da Clarion no setor de oleaginosas. Posteriormente, segundo eles, a Companhia decidiu realizar o arrendamento da unidade industrial à P.A.C. por conta da insuficiência provisória de capital de giro para a exploração do ativo, tendo tal arrendamento durado poucos meses.

27. No que se refere à avaliação dos bens cujos créditos foram utilizados para subscrever o aumento de capital de 30.12.2008, sustentaram que o art. 170, §3º, e consequentemente também o art. 8º, ambos da Lei nº 6.404/76, não seriam aplicáveis, pois o aumento não teria envolvido subscrição de ações com realização em bens, mas com créditos decorrentes de contrato de mútuo. Ressaltaram, ainda, que esses ativos foram objeto de avaliação por parte da E.M.

28. De outra parte, a área técnica solicitou esclarecimentos a respeito da celebração de contrato de mútuo em 27.7.2006 entre a Clarion e a Manacá, cujo crédito também foi utilizado no aumento de capital deliberado pelo conselho de administração em 30.12.2008. Tal contrato previa que a Manacá, sempre que tivesse capital disponível, deveria depositar o valor por ela estipulado em conta conjunta com a Clarion, que, por sua vez, poderia realizar saques sem restrições. Em contrapartida, a Clarion deveria pagar, mensalmente, quantia equivalente a 1,8% dos saldos diários da conta. Caso, no entanto, a referida conta-corrente apresentasse saldo negativo, a obrigação de realizar esse pagamento se transferiria à Manacá. Em decorrência desse contrato, como já informado, a Companhia tornou-se devedora de sua controladora no valor de R\$ 111.694.412,27.

29. Em resposta, Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho, Paulo César de Moura Bueno e Alexandre Bride alegaram que o aludido contrato foi celebrado em condições comutativas principalmente em função do disposto em sua cláusula segunda, segundo a qual a Manacá deveria remunerar a Clarion caso a conta conjunta dessas sociedades apresentasse saldo devedor¹⁷.

30. A SEP também solicitou manifestações sobre a aquisição, pela Clarion, da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007, em que, segundo a área técnica, *"foram utilizados recursos da Companhia no montante de R\$ 58.261 mil, sem que houvesse capital de giro para explorar o negócio, obtendo remuneração de 0,51% sobre este valor em arrendamento do ativo à sociedade ligada ao controlador, ao passo que a Companhia estava incorrendo em juros de 1,8% ao mês decorrente do contrato de mútuo firmado com a controladora em 27.07.06"*.

31. Em resposta, Paulo César de Moura Bueno e Alexandre Bride reiteraram que a aquisição teve por objetivo permitir uma atuação integrada da Clarion no setor de

oleaginosas, tendo a insuficiência de capital de giro sido constatada somente logo após tal aquisição. Assim, o arrendamento, que se deu de forma provisória e excepcional, teria sido a melhor decisão aos interesses da Clarion.

32. Em relação à remuneração adotada para o arrendamento, esses acusados manifestaram-se no sentido de que não caberia uma comparação com a remuneração paga pela Companhia no âmbito do contrato de mútuo celebrado com a Manacá um ano antes, equivalente a 1,8%. A principal diferença, segundo eles, se dá no valor base sobre o qual incidiam tais percentuais. De acordo com suas manifestações, "(...) enquanto que o primeiro incidiu sobre um valor fixo (R\$ 58.261 mil), o segundo incidiria sobre um valor variável, conforme demonstram os itens '1' e '2' do Contrato de Mútuo".

33. Dessa forma, o cálculo do percentual estipulado já considerava que os montantes que seriam depositados pela controladora (a Manacá) poderiam ser baixos, além de imprevisíveis. Nessas condições, concluiu-se que o percentual adotado seria o mais razoável.

34. Finalmente, a SEP solicitou a manifestação de Alexandre Bride quanto ao Formulário de Referência 2011, versão 3.0, no qual não constariam as informações exigidas pelo Anexo 24, item 16, da Instrução CVM nº 480/2009, especificamente em relação ao contrato de mútuo firmado em 27.7.2006 e "*aos contratos cujos bens objeto foram utilizados, de forma indireta, na subscrição de aumento de capital de 30.12.08*". Em resposta, o acusado comprometeu-se a encaminhar as informações mencionadas e a retificar o Formulário de Referência até o dia 15.11.2011.

III. DAS ACUSAÇÕES E DAS DEFESAS

35. Após analisar os fatos, as reclamações e as manifestações apresentadas, a SEP apresentou termo de acusação em face dos acusados no dia 10.2.2012 (fls. 509-552). Em 11.5.2012, os acusados Alexandre Bride, José Martins Pereira, José Roberto Amoriello, Paulo César de Moura Bueno, Regina Martins Ferrari, Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho apresentaram defesa conjunta, tendo Oriel Campos Leite apresentado sua defesa individualmente em 7.5.2012.

III.1. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 30.12.2008

III.1.a. Acusação

36. De acordo com a acusação, a sequência de fatos encadeados na reunião do conselho de administração de 30.12.2008 – a aquisição dos ativos da Manacá e da M.A. pela Clarion, a celebração de contratos de mútuo desses ativos em favor dessas sociedades e a utilização dos créditos desses contratos para o aumento de capital em favor da controladora – demonstra que referido aumento foi subscrito pela Manacá mediante integralização com bens.

37. No entender da SEP, ao proceder dessa forma, os acusados visaram a afastar a aplicação dos artigos 170, §3º, 122, VI¹⁸, e 115, §1º¹⁹, da Lei nº 6.404/76, que, em suma, condicionariam o aumento à aprovação da assembleia geral, em cuja deliberação a Manacá estaria impedida de votar.

38. A acusação ressaltou que a unidade produtora de álcool situada no município de Ibaiti, Paraná, adquirida da Manacá pela Clarion em 30.12.2008, foi avaliada pela E.M. em R\$ 452.350.000,00. Em seguida, ao analisar a certidão do Registro de Imóveis da Comarca de Ibaiti, datada de 4.7.2011²⁰, *"verific[ou] que consta do documento que o imóvel foi transferido pela Manacá à Clarion apenas em 30.06.11 (o aumento de capital com a integralização com esse bem se deu em 30.12.08), com base em Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 06.06.11, pelo valor de R\$ 400.000,00, elevado para R\$ 800.000,00 pela prefeitura da cidade"* (fls. 537 e 538, grifos do original).

39. O termo de acusação observou que não consta dessa certidão o valor das máquinas e equipamentos que integravam o imóvel, mas que, mesmo assim, a diferença entre o valor da avaliação da E.M. e o valor utilizado para integralização do aumento de capital seria significativa.

40. A área técnica também destacou que a operação de aumento de capital foi executada em duas etapas, quais sejam: *"(i) transações entre partes relacionadas, envolvendo a compra e venda de ativos, seguidas da constituição de contratos de mútuo em favor do acionista controlador; e (ii) posterior integralização do aumento de capital com parte dos créditos constituídos"* (fl. 530). Tendo essas etapas ocorrido simultaneamente e considerando o fato de que os contratos de mútuo foram celebrados com o único objetivo de serem utilizados no aumento de capital em favor da Manacá, a acusação alegou ter sido realizado *"negócio indireto"* por parte dos envolvidos.

41. Nesse sentido, ressaltou que a Procuradoria Federal Especializada – PFE concordou com esse entendimento ao ressaltar, no âmbito do MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 74/10 (fls. 232 a 235), que a operação teria sido realizada em fraude à lei, restando caracterizada a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil²¹.

42. A acusação também ressaltou que todos os conselheiros que aprovaram a operação foram eleitos pela Manacá, a única beneficiada pelo aumento de capital, tendo os acionistas que não exerceram o direito de preferência sido diluídos em 1.429%, ao passo que a participação da controladora aumentou de 95,57% para 99,74%. Além disso, afirmou não haver indícios de que os conselheiros tenham se beneficiado da operação e destacou que a Manacá foi contraparte dos contratos de mútuo celebrados com a Clarion, cujos créditos seriam utilizados exclusivamente para subscrição de aumentos de capital.

43. Diante disso, tendo em vista que o quadro social da Manacá é composto por Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, titulares, respectivamente, de 0,5% e 99,5% do seu capital social, a SEP entendeu que esses acusados descumpriram o disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. De outra parte, a acusação alegou que José Roberto Amoriello, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, conselheiros presentes à reunião do conselho de administração da Clarion ocorrida em 30.12.2008, descumpriram o art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76, por não terem observado o procedimento estabelecido para a integralização de ações em bens.

44. Adicionalmente, com base na ata da reunião do conselho de administração, a SEP também concluiu que o critério de precificação das ações então emitidas não foi pormenorizadamente justificado. De acordo com o termo de acusação,

"não constou (...) a justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério adotado na determinação do preço de emissão, nos termos do §7º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, tampouco as razões pelas quais os conselheiros de administração da Companhia entenderam que o valor patrimonial representava, à época, o valor justo a ser atribuído às ações emitidas no aumento de capital, de modo a evitar a diluição injustificada da participação dos antigos acionistas" (fls. 536 e 537).

45. Nesse sentido, a área técnica ressaltou que o simples fato de não haver cotação das ações de emissão da Clarion não justificaria a adoção exclusiva do critério do valor patrimonial para a fixação do preço de emissão dos papéis, uma vez que a perspectiva de rentabilidade da Companhia também deveria ter sido considerada como alternativa.

46. Ademais, a SEP destacou que, (i) em suas manifestações²², os acusados limitaram-se a informar que a adoção do valor patrimonial se deu por não haver, à época, negociação em bolsa das ações de emissão da Clarion e que a perspectiva de rentabilidade seria critério mais adequado para casos de aquisição ou venda de uma empresa; e (ii) para acompanhar a participação que possuía no capital social da Companhia, a reclamante M.C.T. teria que integralizar R\$ 19.229.789,34 à vista no aumento em questão.

47. Assim, sugeriu a responsabilização dos conselheiros José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, quando da aprovação do aumento de capital no âmbito da reunião do conselho de administração de 30.12.2008, por não terem apresentado justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

III.1.b. Defesa

48. Em relação à acusação de descumprimento do disposto nos artigos 116, parágrafo único – imputada a Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho –, e 170, §3º, da Lei nº 6.404/76 – imputada a José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite –, as defesas reiteraram que o aumento de capital questionado foi integralizado com créditos, sendo inaplicável, portanto, a forma estabelecida para a integralização em bens. Além disso, afirmaram que a deliberação conjunta das matérias objeto da reunião do conselho de administração de 30.12.2008 é absolutamente legítima e não encontra vedação na legislação.

49. Sobre a acusação de descumprimento ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, devido à falta de justificativa pormenorizada a respeito da escolha do critério de fixação do preço de emissão das ações da Clarion quando do aumento de capital de 30.12.2008, imputada aos conselheiros José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, as defesas destacaram que a SEP não teria indicado o que consistiria uma justificativa pormenorizada.

50. Reiteraram que optaram por utilizar o valor patrimonial da ação com base no balanço mais recente da Companhia, o que refletia a real situação da Clarion. A esse respeito, as defesas invocaram o Parecer de Orientação CVM nº 1/78, segundo o qual *"não será intenção da CVM pretender entrar no mérito do preço de emissão de ações, interferindo, deste modo, no mercado"*.

51. O Parecer de Orientação CVM nº 5/79 também foi mencionado, quando alegaram que a cotação das ações *"consiste em elemento fundamental para a exata aferição do patrimônio atual do acionista,"* representando o *"real 'valor econômico' (de troca) da ação (...)"*. Argumentaram, por fim, que, como não foi possível considerar a cotação das ações da Clarion em bolsa, foi utilizado o valor do patrimônio líquido. Citaram, ainda, precedentes desta CVM envolvendo a *business judgment rule* e alegaram que, por terem decidido o critério de fixação do preço de forma informada, refletida e desinteressada, não caberia à Autarquia interferir nessa decisão.

III.2. DO CONTRATO DE MÚTUO DE 27.7.2006

III.2.a. Acusação

52. De acordo com o Termo de Acusação, o contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006, subscrito pelos então diretores da Companhia Alexandre Bride e José Martins Pereira, que também foi utilizado para integralização no aumento de capital ocorrido em 30.12.2008, sujeitou a Companhia ao arbítrio da Manacá. Isso porque tal instrumento *"estabelec[ia] obrigações à Clarion – pagamento de juros de 1,8% a.m. sobre o valor depositado, independente da necessidade desses recursos pela Companhia – quando o acionista controlador entender conveniente realizar depósitos, a seu exclusivo critério. Além disso, o contrato fornec[ia] ao controlador um meio de obter uma rentabilidade fixa de 1,8% ao mês sobre o valor que lhe convier, à custa da Companhia"* (fl. 539).

53. O termo de acusação destacou, ainda, que a taxa mensal estabelecida, de 1,8%, equivale a uma taxa anual de 23,87%. Também enfatizou que, conforme o laudo de avaliação da E.M. que atribuiu o valor de R\$ 452.350.000,00 à unidade produtora de álcool, foi utilizado o método do fluxo de caixa descontado a taxa equivalente ao custo médio ponderado de capital.

54. De acordo com a área técnica, *"essa taxa corresponde a uma média ponderada entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros (que reflete a taxa de juros paga em financiamentos obtidos de terceiros). O custo do capital próprio foi calculado em 7,65% e o custo do capital de terceiros 13% aa., que resultaram em um custo médio ponderado de capital de 11,02%"* (fl. 540, grifos do original).

55. Assim, a SEP pontuou que, ao contrário do que esperava, a taxa relativa ao contrato de mútuo – 23,87% – e a utilizada no laudo de avaliação – 13% – são significativamente diferentes.

56. Afirmou, então, que isso poderia indicar duas coisas: que (i) a taxa do contrato de mútuo é excessivamente alta, indicando não comutatividade; ou que (ii) a taxa calculada no laudo foi subavaliada, resultando em maior valor para o ativo. Logo, a Manacá teria integralizado o aumento de capital de 30.12.2008 com valor acima do devido, aumentando sua participação irregularmente.

57. Por isso, de acordo com a acusação, Alexandre Bride e José Martins Pereira, subscritores do contrato de mútuo em tela, devem ser responsabilizados por violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/76.

58. A acusação também entendeu que Paulo César de Moura Bueno, diretor executivo da Companhia, deve ser responsabilizado pela mesma infração, com base no §1º do art. 158 da Lei nº 6.404/76²³. Apesar de não ter assinado o contrato, a SEP levou em conta que esse diretor *"não foi contrário à assinatura do referido contrato, tampouco deu ciência à Diretoria de sua eventual oposição"* (fl. 540). Além disso, a acusação também considerou o fato de ele ter defendido a comutatividade do contrato em sua manifestação prévia²⁴.

59. Aos acusados Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, por sua vez, na qualidade de acionistas controladores da Clarion, foi sugerida a imputação de responsabilidade por infração ao art. 117, §1º, alínea f, da Lei nº 6.404/76²⁵, por terem contratado com a Companhia em condições não equitativas.

III.2.b. Defesa

60. Em relação à acusação de violação ao art. 245 da Lei nº 6.404/16 por parte de José Martins Pereira, Alexandre Bride e Paulo César de Moura Bueno, a defesa alegou que a comutatividade do contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006 é expressa na cláusula segunda desse instrumento, *"uma vez que previa que a contrapartida em prol da Clarion estaria no pagamento, pela Manacá, do equivalente a 1,8% ao mês sobre os saldos devedores da conta conjunta mencionada"* (fl. 652). Isso indicaria um equilíbrio contratual que *"é reforçado quando se constata que a Clarion tem naquele contrato um meio ágil e menos custoso de obtenção de recursos para o cumprimento dos seus objetivos sociais"* (fl. 652).

61. Argumentou que o art. 6º, II, da Deliberação CVM nº 538/2008 não teria sido atendido, pois a acusação teria se baseado apenas em interpretação parcial do referido contrato de mútuo, sem que se tenha averiguado ou demonstrado se a Clarion sofreu ou não prejuízos com a operação. Não seria possível concluir, então, que os acusados José Martins Pereira e Alexandre Bride tenham favorecido a Manacá. Além disso, a defesa sustentou que a ausência de dano afastaria a responsabilidade administrativa desses acusados.

62. Especificamente sobre o acusado Paulo César de Moura Bueno, que não assinou o mencionado instrumento, a defesa reforçou os argumentos descritos acima e ressaltou que ele não teve conhecimento do contrato. Nesse sentido, afirmou que *"(i) não foi demonstrada a data em que o Defendente Paulo César de Moura Bueno teve conhecimento do contrato; (ii) consequentemente, não foi possível concluir se o silêncio do mesmo, ao não dar ciência imediata de eventual discordância à época se deveu simplesmente ao não conhecimento do contrato"* (fl. 655).

63. A defesa também destacou que o fato de esse acusado *"ter defendido a comutatividade em manifestação muito posterior à celebração do contrato não implica reconhecer que, à época, tomou ciência e concordou com o mesmo, mas apenas que, passados estes anos, não foi constatada qualquer ausência de comutatividade, ou situação que tenha gerado prejuízo à Clarion"* (fl. 655).

64. A respeito da acusação de prática de abuso de poder de controle, em violação ao art. 117, §1º, "f", da Lei nº 6.404/76, por conta da celebração do contrato de mútuo de 27.7.2006, a defesa argumentou que o mencionado dispositivo exige a presença de dano para a responsabilização do acionista controlador. Nesse sentido, reiterou que a SEP não demonstrou o prejuízo financeiro sofrido pela Clarion em razão da celebração do contrato, motivo pelo qual a acusação seria improcedente.

III.3. DO ARRENDAMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL OBJETO DO FATO RELEVANTE DE 25.7.2007

III.3.a. Acusação

65. Em 1.9.2007, como já descrito, a Clarion arrendou a unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007 à sociedade P.A.C., cujos quotistas eram A.L.C.A. e R.M.F., sendo este filho e irmão, respectivamente, de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho. Conforme apurado pela SEP, o valor recebido pela Companhia em contrapartida ao arrendamento foi de R\$ 300.000,00 por mês, tendo o respectivo contrato perdurado até 15.2.2008.

66. De acordo com o termo de acusação, *"a Companhia pagou **R\$ 58.261 mil** para receber uma remuneração de R\$ 300 mil mensais, que corresponde a uma taxa de remuneração de **0,51%** a.m. sobre o montante pago, ligeiramente superior à taxa de remuneração da poupança"* (fl. 541, grifos do original).

67. Considerando a resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº104/11, no sentido de que o arrendamento foi realizado por conta da falta de capital de giro da Clarion para a exploração da unidade industrial em questão, *"os diretores, cientes da situação financeira da Companhia, **não atuaram com a diligência requerida no art. 153 da LSA ao adquirir a unidade mencionada, restando configurado também o desvio de poder de que trata o art. 154 da LSA**, uma vez que utilizaram recursos da Companhia no montante de **R\$ 58.261 mil**, sem que houvesse capital de giro para explorar o negócio, obtendo remuneração de **0,51%** sobre este valor em arrendamento do ativo à sociedade ligada ao controlador, ao passo que a Clarion estava incorrendo em juros de **1,8%** ao mês decorrente do contrato de mútuo já citado, o que não pode representar o interesse da Companhia"* (fl. 542, grifos do original).

68. A acusação argumentou que, uma vez que as unidades foram adquiridas da Manacá, os controladores poderiam ter arrendado o ativo diretamente à P.A.C., auferindo os R\$ 300.000,00 mensais, tendo sido desnecessária a sua alienação à Companhia. *"Essa conduta",* prosseguiu, *"só fez aumentar (ou deixar de diminuir) o valor da dívida relativa ao contrato de mútuo de 27.07.06, que foi integralmente utilizado no aumento de capital de 30.12.08, em proveito do controlador"* (fl. 542). Assim, teria havido, indiretamente, uma diluição injustificada dos antigos acionistas.

69. A SEP destacou que, além desse fator, a responsabilidade dos controladores não pode ser afastada também pelos seguintes motivos: (i) o contrato de arrendamento foi assinado por R.M.F., filho e irmão dos acusados Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, respectivamente; e (ii) os acusados Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho e a

P.A.C., sociedade da qual R.M.F. detinha 50% das quotas, foram os únicos beneficiados pela operação.

70. Pelo acima exposto, a acusação concluiu que os acusados Alexandre Bride, Paulo César de Moura Bueno e José Martins Pereira violaram o disposto nos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/76, ao passo que Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho devem ser responsabilizados por infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

III.3.b. Defesa

71. No que se refere à imputação a Alexandre Bride, Paulo César de Moura Bueno e José Martins Pereira de responsabilidade por infração ao disposto nos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/76, afirmou a defesa que a acusação não teria considerado que, entre a decisão pela aquisição da unidade industrial e o seu posterior arrendamento, decorreu-se o período de aproximadamente um mês. Durante esse período, a dinâmica dos negócios da Companhia permitiria justificar a mudança da sua situação financeira.

72. Nessa linha, a defesa argumentou que *"a [SEP] ignora em sua acusação que à época da decisão gerencial pela aquisição dos ativos, a situação financeira era distinta da que viria a se apresentar quando da decisão pelo arrendamento"* (fl. 658).

73. Também destacou que os ativos arrendados proporcionaram faturamento de R\$103.300.000,00, tendo a decisão atendido unicamente aos interesses da Clarion, não se demonstrando qualquer desvio de poder por parte dos acusados. Como discorreu a defesa, *"o fato de a empresa ter arrendado os ativos um mês após, e por poucos meses, em razão da insuficiência do capital de giro, deve ser considerado à luz da dinâmica do ramo de atuação da Clarion, pois é absolutamente natural que tal indisponibilidade, por diversos fatores, possa ocorrer em um curto espaço de tempo"* (fl. 659).

74. Destacou, ainda, que, ao comparar a remuneração da Clarion de 0,51% sobre o valor da aquisição do ativo objeto do arrendamento com os juros de 1,8% ao mês que a Companhia estava incorrendo em razão do contrato de mútuo de 27.7.2006, a acusação considerou fatos distintos, que não se confundem, para justificar uma conclusão improcedente.

75. Na direção do alegado em suas manifestações prévias, os acusados sustentaram que a base de cálculo de ambos os percentuais não foi considerada. Em suas palavras, *"(...) enquanto que pelo arrendamento celebrado em 2007, a Clarion seria remunerada pelo equivalente a 0,51% do preço de aquisição dos ativos – o que correspondeu a R\$ 300.000,00 por mês – o contrato de mútuo celebrado um ano antes obrigaria a Clarion a remunerar a Manacá pelo valor correspondente a 1,8%, sobre a quantia disponibilizada em conta conjunta mantida pelas empresas, ou seja, sobre um valor variável e não demonstrado pela [SEP], especialmente até a celebração do arrendamento em 2007"* (fl. 660).

76. Assim sendo, comparando-se as operações, não seria possível concluir que a Clarion sofreu prejuízo com base apenas no percentual aplicado. Em um caso, conforme a defesa, tratou-se de base de cálculo com valor fixo, em outro, de base de cálculo com valor variável.

77. Ainda a respeito do arrendamento, a defesa ressaltou que apenas o acusado José Martins Pereira subscreveu o respectivo contrato, não tendo a SEP fundamentado a acusação dirigida a Paulo César de Moura Bueno e Alexandre Bride.

78. No que se refere à atuação dos acionistas controladores, Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, acusados por suposta infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, por conta da aquisição da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007 e a posterior celebração de contrato de arrendamento com a P.A.C., em 1.9.2007, a defesa argumentou que tal imputação se revela insubsistente quando analisado o cronograma dos fatos.

79. Nesse sentido, os acusados elaboraram a seguinte tabela, transcrita em seus termos originais (fl. 677):

Data	Fato
25.7.2007	Data do fato relevante em que foi divulgada a aquisição dos ativos da Manacá, pela Clarion.
1.9.2007	Arrendamento dos ativos à [P.A.C.].
15.2.2008	Término do arrendamento dos ativos.
30.12.2008	Reunião que deliberou o aumento de capital da Clarion, em que a Manacá utilizou o crédito detido contra aquela para a integralização das ações emitidas.

80. A defesa ressaltou que, quando do aumento de capital, *"o arrendamento dos ativos **já havia terminado há mais de 10 meses**, o que significa que encontravam-se em plena posse da Clarion, proporcionando resultados significativos para esta"* (fl. 677, grifos do original). A acusação, prosseguiu a defesa, só faria sentido se o arrendamento tivesse se estendido até o dia em que a Manacá integralizou o aumento de capital com os créditos por ela detidos.

81. Considerando, sobretudo, o potencial de faturamento dos ativos em questão, a aquisição teria atendido aos interesses da Companhia. Segundo a defesa, *"o arrendamento dos ativos um mês após a aquisição, e por poucos meses, em razão da insuficiência do capital de giro, deve ser considerado à luz da dinâmica do ramo de atuação da Clarion, pois é absolutamente natural que tal indisponibilidade, por diversos fatores, possa ocorrer em um curto espaço de tempo"* (fl. 678). Assim, não se poderia vislumbrar violação ao parágrafo único do art. 116 da Lei nº 6.404/76.

III.4. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 28.6.2010

III.4.a. Acusação

82. O termo de acusação destacou que a Manacá integralizou, com créditos que detinha contra a Clarion (decorrentes do contrato de mútuo firmado em 27.7.2006), a totalidade do aumento de capital de 28.6.2010, no qual o capital da Companhia passou de R\$ 800.000.000,00 para R\$ 1.000.070.000,00.

83. Também foi ressaltado que o aumento causou diluição de aproximadamente 36,13% aos acionistas que não exerceram o direito de preferência e que *"o preço de emissão foi fixado em R\$ 9,50 por ação, que representa um deságio de 9,18% sobre a*

média de cotação das ações PN de emissão da Clarion no período compreendido entre 04.01.10 e 10.06.10” (fl. 543).

84. Com base na justificativa apresentada pelo conselho de administração, a SEP, além de ter destacado que apenas 22 negócios foram executados com ações preferenciais de emissão da Companhia nesse período, representando um montante total de R\$ 106.081,00, asseverou que, *“embora a Companhia tenha descrito a forma de cálculo do preço de emissão, não houve justificativa pormenorizada para a adoção do critério de cotação em detrimento dos critérios de valor econômico e de PL contábil da Companhia, cabendo ressaltar que, considerando o número e volume de negócios ocorridos com os papéis preferenciais da Clarion no período, a informação se mostrava significativamente relevante”* (fls. 543 e 544).

85. Sendo assim, José Roberto Amorielo foi acusado de ter violado o disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, pois, na qualidade de conselheiro da Clarion, não teria apresentado justificativa pormenorizada para a adoção do critério de fixação do preço das ações então emitidas.

86. Ainda no âmbito dessa reunião, a acusação apontou a existência de conflito de interesses por parte de Reno Ferrari (então presidente do conselho de administração e acionista da Manacá) e Regina Martin Ferrari (então vice-presidente do conselho, filha de Reno Ferrari e irmã de Reno Ferrari Filho).

87. O conflito teria se dado porque, quanto menor o preço de emissão das ações, maior seria o acréscimo na participação da Manacá na Companhia. No entender da SEP, uma vez que Reno Ferrari possuía ações de emissão da Manacá, ele estaria impedido de deliberar a fixação de preço de emissão na mencionada reunião. Do mesmo modo, por ser filha e irmã dos acionistas da Manacá, Regina Martin Ferrari também estaria impedida de participar da referida deliberação. Assim, esses acusados teriam, segundo a acusação, infringido o disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/76.

88. Contudo, em reunião ocorrida em 19.5.2015, o Colegiado da CVM decidiu conferir nova definição jurídica aos fatos apurados relativos a Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, nos termos dos artigos 25²⁶ e 26²⁷ da Deliberação CVM nº 538/2002. De acordo com o despacho por mim proferido (fls. 692-698), não restou demonstrada a existência de conflito entre o interesse desses conselheiros e o da Clarion, pois um maior ou menor preço de emissão não feriria os interesses dessa Companhia.

89. Contudo, tendo em vista que (i) a Lei nº 6.404/76 adotou, em seu art. 170, regime cogente para a fixação do preço de emissão das ações nos aumentos de capital, cuja finalidade principal é a proteção contra o risco de diluição abusiva dos acionistas; e que (ii) foi com base nesse regime que a SEP considerou que José Roberto Amorielo, conselheiro da Clarion também presente à reunião do conselho de administração de 28.6.2010, deveria ser responsabilizado por não ter justificado pormenorizadamente a escolha do critério de precificação de ações a serem emitidas, em suposta infração ao disposto no §7º do citado art. 170, o Colegiado entendeu que, por ser o conselho de administração órgão colegiado, a mesma responsabilidade seria cabível, ao menos em tese, em relação aos demais conselheiros que estavam presentes à reunião e deliberaram a fixação do preço de emissão das ações.

90. Sendo assim, a conduta de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari passou a ser analisada à luz do disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76. Como a acusação de descumprimento do estabelecido pelo art. 156 foi alterada, somente os argumentos de defesa relativos à nova definição dos fatos serão descritos a seguir.

III.4.b. Defesa

91. Em relação à acusação imputada a José Roberto Amoriello, na qualidade de conselheiro da Clarion, de descumprimento ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, quando do aumento de capital deliberado em 28.6.2010, no sentido de que a escolha do critério de precificação das novas ações não teria sido pormenorizadamente justificada, a defesa reiterou os argumentos apresentados em relação ao aumento de capital de 30.12.2008, conforme descritos no item 0 acima.

92. Adicionalmente, argumentou que o procedimento estabelecido pela Instrução CVM nº 481/2009 em seu quesito 5, letra i – *"Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha"* – foi rigorosamente cumprido.

93. Em resposta à observação da acusação de que apenas 22 negócios foram executados com as ações preferenciais de emissão da Companhia no período, pontuou que definir o número mínimo de negócios em bolsa que justifique a utilização do critério de cotação das ações compete ao poder discricionário dos administradores, uma vez que a regulação não define o parâmetro objetivamente. Afirmou, então, *"que o número de negócios realizados no período considerado pelos administradores da Clarion, para o aumento de capital deliberado em 28.6.2010, foi significativo o suficiente para a sua adoção"* (fl. 673) e que a cotação da ação seria o parâmetro que melhor representa o valor econômico da ação.

94. Destacou, ainda, que o deságio realizado sobre o preço médio das ações teve como propósito a criação de atratividade adicional para que os antigos acionistas subscrevessem o aumento de capital em quantidade proporcional às suas participações da Companhia. Não se sustentaria, portanto, a alegação da acusação no sentido de que a decisão adotada tenderia à diluição injustificada dos acionistas minoritários.

95. Os acusados Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, por sua vez, no âmbito do aditamento às suas defesas conjuntamente apresentado, ponderaram que o aumento de capital seria legítimo, tendo afirmado que seu objetivo era a ampliação das atividades da Clarion, *"contemplando seu objeto social, com reforço do capital de giro e redução do endividamento"* (fl. 738).

96. Em seguida, fizeram referência, resumidamente, à expectativa que existia no sentido de que os acionistas subscrevessem o aumento, pois obteriam descontos no preço das emissões em comparação com a cotação das ações em bolsa. Nesse sentido, afirmou a defesa que os acionistas foram avisados que, em caso de não exercício do direito de preferência, *"as sobras sem tomador imediato poderiam ser destinadas a terceiros ou vendidas em bolsa"* (fl. 739).

97. Posteriormente, alegaram que *"[o]s preços da futura emissão de ações foram fixados sem diluição 'injustificada' da participação dos acionistas, ou seja, ante a*

vedação de emissão por preço menor anteriormente subscrito (artigo 13 da LSA), foram precificadas por melhor preço, dentro do estabelecido legalmente, ou seja, pelo valor patrimonial líquido de cada ação” (fl. 739).

98. A justificativa, segundo a defesa, *“é que o preço deveria refletir o real valor das ações no momento da subscrição, que, por sua vez, é decorrência direta do valor econômico da Companhia emissora, ou seja, a salvaguarda dos interesses de acionistas não é suficiente para manter a mesma proporção no capital social, porquanto o efeito é apenas numérico (fl. 739)”*

99. Mencionaram que ela foi realizada visando à aproximação máxima ao preço justo e *“com previsão na perspectiva de rentabilidade da Companhia, valor do patrimônio líquido da ação e posterior cotação das ações em bolsa ou mercado organizado, ou de forma, isolada, mas sempre de modo a produzir o resultado mais adequado à Companhia e aos acionistas” (fls. 739-740).*

100. Por fim, no âmbito dos aditamentos às defesas, os acusados Reno Ferrari, Reno Ferrari Filho, Regina Martin Ferrari, Alexandre Bride, José Martins Pereira, José Roberto Amoriello e Paulo Cesar de Moura Bueno alegaram ter ocorrido tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição quinquenal no presente processo.

101. De acordo com as defesas, teria transcorrido mais de cinco anos para a pretensão punitiva da Administração Pública Federal, contados da prática dos supostos ilícitos imputados aos acusados, bem como o decurso de três anos de paralisação do processo pendente de julgamento. A propósito, afirmaram que o *“termo de acusação prolatado”* e a redefinição jurídica dos fatos não possuem o condão de interromper os respectivos prazos, uma vez que seriam consideradas insubsistentes em relação aos acusados.

III.5. DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 2011

III.5.a. Acusação

102. A acusação alegou, por fim, que Alexandre Bride, na qualidade de diretor de relações com investidores da Clarion, deveria ter divulgado as informações relativas aos contratos de mútuo de 27.7.2006 e 30.12.2008. No entanto, quando da análise do Formulário de Referência 2011, versão 3.0, já reapresentado à CVM por determinação do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 137/11, de 1.8.2011, constatou-se que nenhuma das informações previstas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM nº 480/2009 foi apresentada pelo acusado.

103. Entendeu a SEP, então, com base no art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009²⁸, que Alexandre Bride deve ser responsabilizado por infração ao art. 13 da mesma Instrução²⁹, segundo o qual *“o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.”*

III.5.b. Defesa

104. Citando o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 137/11, de 1.8.2011 (fl. 371), a defesa argumentou que a CVM não solicitou, em momento algum, que o acusado

apresentasse as informações exigidas no item 16 do Formulário de Referência. A Autarquia, conforme ressaltou, somente teria determinado a apresentação das informações exigidas nos itens 15.1 e 15.2 do Formulário, o que foi devidamente atendido pelo acusado.

105. A exigência para apresentação das informações referidas no item 16 somente foi realizada por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 228/11, de 18.10.2011 (fl. 434), que foi igualmente atendido, conforme Formulário de Referência 2011, versão 4.0. Assim sendo, o termo de acusação teria ignorado informação disponível no próprio *website* da CVM.

106. Com base no art. 58 da Instrução 480/2009³⁰, que estabelece a aplicação de multa diária em virtude do descumprimento dos prazos previstos nessa instrução normativa, a defesa também alegou que, em se tratando de não envio de informação periódica, nos termos do art. 13 da mesma instrução, aplica-se o procedimento estabelecido pela Instrução CVM nº 452/2007, que dispõe sobre multas cominatórias.

107. Em seguida, a defesa invocou o art. 5º da Instrução CVM nº 452/2007³¹, que, no seu entendimento, prevê que a instauração de processo administrativo sancionador *"só seria permitida para a hipótese caso a obrigação de prestação somente fosse cumprida após a fluência da multa ordinária – o que não ocorreu – ou após prazo limite de 60 (sessenta) dias – que igualmente não ocorreu"* (fl. 685). Logo, no entender da defesa, o processo deveria ser arquivado.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

108. A Procuradoria Federal Especializada – PFE³² examinou a primeira versão do termo de acusação, encaminhado pela SEP em 17.11.2011 (fls. 453 a 497), e entendeu não terem sido preenchidos os requisitos previstos no art. 11³³ e nos incisos III e IV do art. 6º³⁴, ambos da Deliberação CVM nº 538/2008 (fls. 499 a 507).

109. Em relação aos requisitos do art. 11, a PFE verificou que José Martins Pereira, Oriel Campos Leite e José Roberto Amoriello, conselheiros da Clarion, não teriam sido diretamente questionados sobre todas as acusações formuladas.

110. No que se refere ao art. 6º, a PFE, primeiramente, entendeu que a conduta dos controladores, quando do aumento de capital e da celebração do contrato de arrendamento, não se enquadraria no art. 117, §1º, "e", da Lei nº 6.404/76³⁵, como originalmente proposto pela SEP, mas, sim, no art. 116, parágrafo único³⁶, pois o controlador não teria atendido com lealdade os interesses da Companhia.

111. A PFE também manifestou entendimento no sentido de que os laudos elaborados por E.M. deveriam ser analisados de forma mais objetiva, pois as informações neles constantes teriam sido tratadas de forma superficial.

112. Além disso, asseverou que haveria necessidade de obtenção de documentação e esclarecimentos suplementares a respeito (i) da composição acionária da Manacá e da M.A.; (ii) dos atos societários da E.M. e dos contratos com ela firmados relativos à elaboração dos laudos; (iii) da relação de Oriel Campos Leite com a reclamante M.C.T., *"em face do mesmo ter votado na qualidade de representante legal desta na votação que aprovou o aumento do capital autorizado da companhia anteriores aos*

aumentos de capital, em 30.04.08" (fl. 506); (iv) das partes que negociaram com as ações preferenciais da Clarion no período de janeiro de 2009 a julho de 2010, em razão das ações ordinárias da Companhia não serem comercializadas em bolsa; e (v) da acusação formulada contra Regina Martin Ferrari, pois os indícios então existentes não seriam suficientes para comprovar sua atuação em conflito de interesses.

113. A SEP manifestou-se a respeito dos entendimentos da PFE em 15.2.2012, conforme a seguir:

- (i) em relação ao não questionamento direto dos acusados José Martins Pereira, Oriel Campos Leite e José Roberto Amoriello, a área técnica afirmou que o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 exige que se obtenha a manifestação dos acusados a respeito dos fatos descritos na peça acusatória, e não das acusações que lhes forem imputadas;
- (ii) a respeito do enquadramento da conduta da acionista controladora como infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, a SEP acatou a sugestão da PFE e alterou a peça acusatória;
- (iii) a área técnica afirmou que não se exige uma avaliação mais profunda dos laudos de avaliação da E.M., pois eles não foram utilizados para justificar o enquadramento das infrações capituladas pela acusação;
- (iv) no que se refere à sugestão da PFE de trazer os documentos e esclarecimentos adicionais mencionados no parágrafo 0 acima, a SEP entendeu que já haveria nos autos elementos suficientes para indicar a prática das condutas irregulares descritas no termo de acusação.

V. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

114. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 17.7.2012, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído ao Diretor Roberto Tadeu em 10.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008³⁷.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ A Clarion teve seu registro de companhia aberta cancelado pela SEP em 18.12.2014, com base no art. 54 da Instrução CVM nº 480/2009, segundo o qual "[a] SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses: (...) II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses."

² Esse valor, conforme explicado pela Clarion, se tratava "de saldo devedor que a Clarion tinha na data 30.12.2008 (que na data foi utilizado para aumento de capital)."

³ O aumento foi aprovado e homologado pelos conselheiros da Clarion em reunião ocorrida em 3.3.2009, passando o capital social da Companhia a ser de R\$ 800.000.000,00, constituído por 12.994.962 ações ordinárias e 16.150.875 ações preferenciais (fl. 208).

⁴ Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 104/11 (fls. 256-259).

⁵ Conforme consta do Formulário de Referência 2011 da Clarion, versão 3.0, reapresentado em 3.8.2011 (fls. 406 e 407).

⁶ "Art. 170. (...)

§3º. A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98.

(...)

§ 7º. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do §1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha."

⁷ Em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 104/11 (fls. 256-259).

⁸ Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº007/09 (fl. 17).

⁹ Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº19/09, de 3.3.2009 (fls. 32 e 33). A SEP também requereu cópias dos seguintes documentos: (i) contratos de compra e venda referentes às aquisições de ativos feitas pela Clarion; (ii) laudos de avaliação desses ativos; e (iii) contratos de mútuo firmados entre a Clarion e a Manacá e a M.A.

¹⁰ "4. Em relação à consideração dos três parâmetros enunciados pelo comentado dispositivo legal, porém, deve-se entender que, embora de observância cumulativa, haverá a prevalência de um outro daqueles três parâmetros sobre os demais, quando da fixação do preço de uma nova emissão daquela ação, conforme o estágio de desenvolvimento do mercado de ações, bem como o tipo de comportamento de uma determinada ação em tal mercado (índice de negociabilidade)."

¹¹ "7. Com relação ao parágrafo "Perspectivas de Rentabilidade" da companhia, ainda, convém se ter presente que além da hipótese normal de sua consideração nos termos acima mencionados, assumirá ele grande significado nos casos em que, mesmo num mercado eficiente, mudanças em tais perspectivas se tenham verificado sem que delas tenha o mercado pleno conhecimento ou assimilado devidamente. Em tais casos, tal parâmetro deverá ser considerado de modo significativo na fixação do preço de emissão das ações da companhia."

¹² O aumento do capital autorizado da Companhia foi deliberado na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 30.4.2009, passando a ser de R\$ 1.500.000.000,00.

¹³ Conforme apurado pela SEP, no âmbito do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 104/11 (fls. 256-259).

¹⁴ Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 104/11 (fls. 256-259).

¹⁵ "Art. 8º - A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

§1º - Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§2º - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão.

§3º - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

§4º - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.

§5º - Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115.

§6º - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária."

¹⁶ As solicitações foram encaminhadas por meio dos seguintes ofícios: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 224/11, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 225/11, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 226/11, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 227/11 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 228/11 (fls. 425-435).

¹⁷ De acordo com a cláusula segunda do contrato de mútuo, "A MUTUÁRIA pagará à MUTUANTE, a título de remuneração, 1,80% pré por mês, sobre os saldos diários da conta corrente, sendo que os valores serão creditados mensalmente no último dia útil do mês, observando o prazo contratual. Caso a conta-corrente venha apresentar saldo devedor, a remuneração deste se dar-se-á nas mesmas bases a favor da MUTUÁRIA."

¹⁸ "Art. 122. Compete privativamente à assembleia-geral:

(...)

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;"

¹⁹ "Art. 115. (...)

§1º - o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia".

²⁰ A certidão foi enviada à SEP pela Clarion em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 104/11.

²¹ "Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (...)."

²² Manifestação proferida em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº019/09.

²³ "Art. 158. (...)

§1º - O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral".

²⁴ Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº226/11.

²⁵ "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

(...)

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;"

²⁶ "Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o disposto na Seção III."

²⁷ "Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a intimação ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado."

²⁸ "Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários."

²⁹ "Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.

§1º REVOGADO

§2º - O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no *caput* em sua página na rede mundial de computadores por 3 (três) anos, contados da data de divulgação.

§3º - As informações enviadas à CVM nos termos do *caput* devem ser entregues simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas estabelecida."

³⁰ "Art. 58 - Nos termos das normas específicas a respeito do assunto, o emissor está sujeito à multa diária em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução para entrega de informações periódicas, no valor de:

I – R\$500,00 (quinhentos reais) para os emissores registrados na categoria A; e

II – R\$300,00 (trezentos reais) para os emissores registrados na categoria B."

³¹ "Art. 5º - Caso a obrigação de prestação de informação somente seja cumprida após fluência da multa ordinária, ou se o prazo limite de que trata o art. 14 for atingido sem que a obrigação seja cumprida, o Superintendente da área responsável decidirá, fundamentadamente, sobre a conveniência da aplicação e cobrança da multa cominatória ou da instauração de processo administrativo sancionador.

§1º - A instauração de processo sancionador será determinada quando o Superintendente concluir que o atraso na prestação da informação causa risco de dano relevante ao mercado ou aos investidores, considerando, para tanto, entre outros fatores, e conforme o caso, o montante e a dispersão dos valores mobiliários de emissão do participante em circulação no mercado, a quantidade dos clientes da entidade supervisionada, os negócios por ela usualmente intermediados, e os valores sob administração, gestão ou custódia.

§2º - O Superintendente somente determinará cumulativamente a cobrança de multa e a instauração de processo sancionador caso entenda que o atraso na prestação da informação é parte de uma conduta mais ampla, que deva ser objeto de sanção administrativa."

³² MEMO nº 131/2011/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

³³ "Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça."

³⁴ "Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

(...)

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;”

³⁵ “Art. 117. (...)

§1º - São modalidades de exercício abusivo de poder:

(...)

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral;”

³⁶ “Art. 116. (...)

Parágrafo único - O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.”

³⁷ “Art. 10 - Ao Diretor que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2011/11073

Acusados: José Martins Pereira
Oriel Campos Leite
José Roberto Amorielo
Paulo César de Moura Bueno
Alexandre Bride
Reno Ferrari
Reno Ferrari Filho
Regina Martin Ferrari

Assunto: Falta de comutatividade em operações entre partes relacionadas (art. 245 da Lei nº 6.404/1976); abuso do poder de controle (artigos 116, parágrafo único, e 117, §1º, “f”, da Lei nº 6.404/76); descumprimento do dever de diligência (art. 153 da Lei nº 6.404/76); desvio de poder (art. 154 da Lei nº 6.404/76); fraude ao procedimento previsto para realização de aumento de capital com bens (art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76); não apresentação de justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão de ações decorrentes de aumento de capital (art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76); não apresentação de informações requeridas no Anexo 24, item 16, da Instrução CVM nº 480/2009 (art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009).

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de acionistas controladores e administradores da Clarion para apurar supostas irregularidades praticadas no âmbito dos aumentos de capital da Companhia deliberados em 30.12.2008 e 28.6.2010 e de transações entre partes relacionadas.

I. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

2. Antes de passar à análise do mérito das acusações, convém enfrentar a preliminar trazida por alguns acusados quanto à ocorrência de prescrição da pretensão

punitiva. De acordo com o alegado, já se passaram mais de cinco anos desde a prática dos atos supostamente ilícitos. Além disso, o processo teria permanecido paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3. A alegação, contudo, não é procedente. De uma parte, a prescrição quinquenal, prevista no *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873/1999¹, foi interrompida em diversas oportunidades no curso deste processo. Mencione-se, a título ilustrativo, o Ofício CVM/SEP/GEA-4/nº 07/09, de 5.2.2009, e o Ofício CVM/SEP/GEA-4/Nº19/09, de 3.3.2009 (fls. 17 e 32-33), ambos encaminhados pela Superintendência de Relações com Empresas ao acusado Alexandre Bride, então diretor de relações com investidores da Clarion, com vistas a obter dados e informações a respeito dos fatos apurados. Tais atos interromperam, inequivocamente, a prescrição quinquenal, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99³. Adiante, os acusados foram intimados para apresentar defesa em 7.3.2012 (fls. 560-567), momento em que ocorreu nova interrupção da prescrição, de acordo com o disposto no inciso I da Lei nº 9.873/99². Em suma, considerando esses fatos interruptivos e considerando, ainda, que o fato mais antigo apurado nos autos ocorreu em 27.7.2006, conclui-se que, neste processo, não se deu a prescrição quinquenal.

4. Tampouco sobreveio a prescrição intercorrente, prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, a qual, de acordo com o entendimento consolidado nesta autarquia, só incide depois de iniciado o processo sancionador, não se aplicando, portanto, ao procedimento apuratório antecedente⁴. Com efeito, após a formulação da acusação, este processo não restou paralisado por mais de três anos, haja vista a prática de diversos atos subsequentes. Mencione-se, entre outros, a distribuição do processo por sorteio em 17.7.2012 (fl. 689) e a decisão do Colegiado proferida em 19.5.2015, que deu nova definição jurídica a fato apurado neste processo (fls. 699-700).

5. Superada a preliminar, passo à análise do mérito das acusações.

II. DO MÉRITO

6. Os fatos apurados neste processo sancionador se dividem em quatro eventos principais: (i) o aumento de capital da Clarion de 30.12.2008; (ii) o contrato de mútuo de 27.7.2006; (iii) o arrendamento da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007; e (iv) o aumento de capital de 28.6.2010. Após analisar as infrações imputadas aos acusados em cada um desses eventos, apreciarei a acusação relativa à ausência de informações dos contratos de mútuo no Formulário de Referência da Clarion do ano de 2011.

II.1. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 30.12.2008

7. Em reunião do conselho de administração realizada em 30.12.2008, os conselheiros da Clarion deliberaram a aquisição de ativos de propriedade da Manacá, então acionista controladora da Companhia, e da M.A., sociedade controlada pela Manacá. Os respectivos contratos de compra e venda celebrados por essas sociedades continham cláusulas que previam que os respectivos preços de compra seriam objeto de contratos de mútuo com a Clarion, nos termos dos quais a Companhia passaria a ser devedora desses valores em favor da Manacá e da M.A.

8. Considerando que o crédito detido pela M.A. foi cedido à Manacá e que já existia, à época, contrato de mútuo celebrado anteriormente entre a Clarion e a Manacá, esta última passou a deter créditos contra a Companhia no valor total de R\$742.962.912,27 (setecentos e quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil e novecentos e doze reais e vinte e sete centavos).

9. No curso da mesma reunião, os conselheiros deliberaram aumentar o capital social da Clarion, tendo a Manacá utilizado os mencionados créditos para integralizar ações.

10. De acordo com a peça acusatória, duas irregularidades teriam ocorrido nessa oportunidade: (i) fraude às normas legais relativas à subscrição de ações para realização em bens; e (ii) falta de justificativa pormenorizada da escolha do critério de fixação do preço de emissão das ações.

II.1.1. Fraude às normas legais relativas à subscrição de ações para realização em bens

11. Em relação ao primeiro ponto, a acusação sustenta que o objetivo de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho – considerados os controladores da Clarion – e dos conselheiros presentes à reunião teria sido o de evitar o procedimento prescrito em lei para a integralização, com bens, de ações. De acordo com a acusação, os acusados teriam realizado “*negócio indireto*”, envolvendo a celebração de compras e vendas e de mútuos, de modo a afastar, ilegitimamente, a incidência do disposto no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/1976.

12. Em virtude desse dispositivo, os bens a serem incorporados ao capital social devem ser previamente avaliados por peritos ou empresa especializada, nomeados em assembleia geral de acionistas. Ademais, o laudo de avaliação deve ser aprovado em assembleia, ficando impedido de votar nessa ocasião o subscritor titular de direito sobre os bens. Somente na hipótese de a avaliação ser aprovada em assembleia é que os bens poderiam ser aproveitados no aumento de capital.

13. No presente caso, tal procedimento não foi observado. Os acusados alegam a respeito que o aumento de capital não foi realizado com bens, mas com os créditos decorrentes dos contratos de mútuo. Sendo assim, não incidiriam ao caso as já mencionadas regras legais. Também argumentam que não se mostra ilícita a aprovação pelo conselho de administração, na mesma reunião, das compras e vendas, dos mútuos e do aumento de capital com o aproveitamento dos créditos.

14. No entanto, as provas dos autos me convencem de que a celebração dos contratos de compra e venda e de mútuo não passou de um artifício para concretizar a realização do aumento com bens, escapando do cumprimento do disposto no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76. Em outras palavras, cuidou-se de estratégia destinada a produzir exatamente o resultado previsto como indesejado pela norma jurídica imperativa, a saber, a incorporação ao capital social de bens cuja avaliação não havia sido aprovada em assembleia geral de acionistas sem o voto do subscritor interessado.

15. O ardil escolhido pelos acusados consistiu na celebração de contratos de compra e venda em fraude à lei, seguida da simulação de contratos de mútuo⁵.

16. Quanto ao primeiro ponto, ninguém ignora que, a princípio, é lícito o ajuste contratual por meio do qual é transmitida determinada coisa em contrapartida ao pagamento pelo adquirente do preço estipulado. No entanto, dadas as circunstâncias do presente caso, resta evidente que os contratos de compra e venda celebrados entre, de um lado, Clarion e, de outro, Manacá e M.A., serviram de meio para viabilizar, indiretamente, a integralização de ações com bens.

17. A fraude é evidenciada pelo fato de tanto a celebração dos contratos de compra e venda quanto a realização do aumento de capital, no qual os créditos seriam aproveitados, terem sido aprovados pelo conselho de administração na mesma reunião, ocorrida em 30.12.2008. Essa circunstância revela que todos os atos consubstanciaram, em realidade, operação econômica unitária, movida por um único desígnio negocial, qual seja, viabilizar a realização do aumento de capital com ativos de propriedade da Manacá e da M.A.

18. De fato, considerando que o aumento de capital foi aprovado simultaneamente aos contratos de compra e venda, resta evidente que a Companhia não tinha a intenção de pagar o preço pactuado pela aquisição dos ativos e tampouco a Manacá tinha a intenção de receber o preço. O fim almejado era, desde o início, a integralização de ações mediante a incorporação ao patrimônio da Companhia dos ativos de propriedade da Manacá e da M.A.

19. Nesse tocante, os acusados alegam que o fato de o conselho ter aprovado tanto as compras e vendas como o aumento de capital em uma mesma reunião não é ilegal. O argumento, contudo, em nada aproveita à defesa, porque, como se sabe, a fraude à lei consiste, justamente, no aproveitamento de meios revestidos de aparente regularidade para o alcance do resultado previsto como indesejado pela norma jurídica.

20. Nesse sentido, já se observou na doutrina que:

“O ato praticado em fraude à lei, se analisado isoladamente, possui todas as características de um ato que estaria em perfeita consonância com a lei. O agente quer efetivamente praticá-lo e submeter-se a todas as suas consequências normais. O problema é que estas consequências estarão produzindo o mesmo resultado que o sistema procura evitar através da norma proibitiva. Se a lei proíbe determinado ato em razão das consequências que produz, não há como possa subsistir ato diverso, mas produtor das mesmas consequências indesejadas, apenas porque não há para ele previsão proibitiva, de natureza objetiva. Em se admitindo o contrário, estaria o sistema jurídico possibilitando a coexistência de duas soluções diversas para uma mesma situação jurídica, algo inconcebível em um sistema que se pretenda coerente⁶.”

21. É exatamente isso que ocorreu no caso ora em apreço: o conselho de administração da Companhia aprovou, na mesma reunião, a celebração de contratos aparentemente regulares com a Manacá e deliberou a realização de aumento de capital, também aparentemente regular, de modo a atingir finalidade, todavia contrária à lei, qual seja, a incorporação de ativos de Manacá e M.A. ao capital social da Companhia sem a observância do procedimento e das salvaguardas estabelecidos no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76.

22. Trata-se, inequivocamente, de fraude à lei, espécie de conduta *contra legem*, que consiste “na utilização de um ato jurídico ou de um complexo de atos jurídicos, os quais, em si, são, em princípio, perfeitamente lícitos, mas atingem efeitos jurídicos pelo menos praticamente equivalentes a determinados efeitos jurídicos que uma norma imperativa considera ilícitos”⁷.

23. De outra parte, os contratos de mútuo, supostamente celebrados, foram, em realidade, apenas simulados, de modo a robustecer a aparente regularidade da operação societária. A esse respeito, vale lembrar que, no direito brasileiro, o mútuo é contrato real, que só se aperfeiçoa com a entrega das coisas fungíveis emprestadas ao mutuário. Nessa direção, o artigo 586 do Código Civil estabelece que o “*mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade*”⁸. A obrigação de restituição, como é curial, pressupõe, necessariamente, que o mutuário tenha adquirido do mutuante a propriedade de coisas equivalentes. Assim é que se não há entrega de coisas fungíveis ao mutuário também não há contrato de mútuo.

24. Ora, no caso em exame, a Manacá e a M.A. não entregaram dinheiro à Companhia por ocasião dos mútuos supostamente celebrados. E nem poderiam, já que, no caso, a Manacá pretendia subscrever ações da Companhia em contrapartida à transmissão dos ativos. Em definitivo, a Companhia não contraiu a obrigação de restituir dinheiro emprestado, como se verificaria no negócio de mútuo. Assumiu, antes disso, a obrigação de entregar as ações a serem emitidas em aumento de capital, em troca da aquisição dos ativos transmitidos. E, como já esclarecido, se não houve entrega de numerário à Companhia nem assunção por esta da obrigação de restituir quantia equivalente, não há que se falar em mútuo.

25. Note-se, ademais, que, no caso em apreço, sequer houve a celebração dos instrumentos contratuais relativos aos mútuos. Nas escrituras de compra e venda, verifica-se, em sentido diverso, que as partes decidiram, sem qualquer justificativa, chamar de *mútuo* o que era *preço*, como se lhes fosse lícito alterar, arbitrariamente, a natureza dos institutos jurídicos. É o que se depreende da leitura das seguintes cláusulas:

(iii) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e Manacá, cláusula segunda, “A”: “O preço certo ajustado para a presente transação é o de R\$ 452.350.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta Mil Reais), objeto de Contrato de Mútuo celebrado entre as partes, cujo instrumento faz parte integrante do presente contrato de Venda e Compra, com a cláusula *pró-soluto*” (fl. 46).

(iv) Contrato de compra e venda celebrado entre Clarion e M.A., cláusula 2.2: “A Compradora pagará à vendedora o valor atualizado na forma do item anterior, em parcela única no dia 30 de dezembro de 2008 mediante contrato de mútuo junto à Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração (Controladora da [M.A.]) cujas partes reconhecem, para todos os fins de direito, como prova de recebimento e de quitação” (fl. 51).

26. Como se vê, não houve, em realidade, contratos de mútuo, mas apenas declarações inverídicas das partes contratantes, que procuraram transvestir o preço em mútuo. Não tenho dúvida, portanto, que se está diante da hipótese de simulação prevista no art. 167 do Código Civil, que resulta da estipulação, no negócio, de “*declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira*”.

27. Em suma, à luz das considerações acima desenvolvidas, é forçoso concluir que, no presente caso, os negócios de mútuo foram simulados para encobrir de aparente regularidade os contratos de compra e venda que, como já visto, foram celebrados em fraude à norma imperativa do art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76.

28. Diante de todo o exposto, entendo que os acusados José Roberto Amoriello, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, que aprovaram a operação no conselho de administração da Companhia, devem ser responsabilizados pela violação ao disposto no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76, que prescreve o procedimento a ser observado na subscrição de ações para realização em bens.

29. Entendo também que o acusado Reno Ferrari Filho, controlador indireto da Companhia, titular de 99,5% do capital social da Manacá (por meio da sociedade estrangeira G.I.C.) e beneficiário final da integralização fraudulenta de ações, deve ser responsabilizado, porque, em infração ao comando do parágrafo único do art. 116 da referida Lei, deixou de atender com lealdade aos interesses dos acionistas da Companhia.

30. Em relação a Reno Ferrari, julgo necessário tecer algumas considerações quanto à condição de controlador que lhe foi atribuída pela SEP. Como apurado, ele possuía, à época dos fatos, apenas 0,5% do capital social da Manacá, sociedade que controlava diretamente a Clarion. De outra parte, não há, nos autos, registro de qualquer acordo de acionistas acerca do exercício do direito de voto ou do poder de controle no âmbito da Manacá, ou da Clarion.

31. O único indício trazido pela acusação de que Reno Ferrari era controlador da Clarion é o fato de ser pai de Reno Ferrari Filho, titular, por meio da sociedade estrangeira G.I.C., dos outros 99,5% das ações de emissão da Manacá.

32. No entanto, convém ressaltar que, nos termos do art. 116, *caput*, da Lei nº 6.404/76, reputa-se controlador "a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia".

33. À luz dessa norma legal, entendo que a existência de vínculo familiar, ainda que estreito, não se mostra suficiente para demonstrar que Reno Ferrari compartilhava o controle da Clarion com o filho. Faltam, nessa direção, elementos de prova aptos a confirmar que Reno Ferrari participava efetivamente da condução das atividades da Companhia.

34. Desta feita, entendo que não devem prosperar as imputações feitas a Reno Ferrari na qualidade de acionista controlador da Companhia.

II.1.2. Falta de justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço

35. Consta da ata da reunião do conselho de administração ocorrida em 30.12.2008⁹ que as ações então emitidas foram precificadas de acordo com o critério

do valor patrimonial porque ainda não teria havido, à época, nenhuma negociação em Bolsa com esses valores mobiliários. A perspectiva de rentabilidade da Companhia, apesar de ser um dos critérios elencados para a fixação do preço de emissão pelo §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, não foi abordada na justificativa, o que, no entendimento da SEP, configuraria violação ao preceituado no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76.

36. Em suas defesas, os conselheiros alegaram que (i) a SEP não teria indicado o que seria uma justificativa pormenorizada; (ii) o valor patrimonial da ação refletiria a real situação da Clarion; e (iii) tendo a decisão sido tomada de forma informada, refletida e desinteressada, não caberia à CVM interferir na escolha do critério de fixação do preço de emissão.

37. Esses argumentos, contudo, não me convencem. O §7º do art. 170 da Lei nº 6.404/76 exige justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que levaram à escolha do critério de fixação do preço de emissão, impondo transparência quanto ao critério adotado e à sua justificativa. Com isso, a Lei possibilita que os acionistas sejam informados e possam supervisionar a atuação dos administradores, avaliando se cumpriram com seus deveres fiduciários quando da tomada de decisão a respeito do preço de emissão das ações a serem subscritas¹⁰.

38. Da leitura da mencionada ata depreende-se que a justificativa apresentada não atendeu às exigências do dispositivo em questão. Como apontado pela acusação, o simples fato de não ter havido negociação em Bolsa das ações de emissão da Clarion não leva, por si só, à utilização do valor patrimonial como critério de precificação. Isso porque, além desses critérios, o §1º do art. 170 também prevê, em seu inciso I, a possibilidade de utilização da perspectiva de rentabilidade da companhia. Assim, a opção por não empregar o referido critério também deveria ter sido abordada na justificativa.

39. Ao contrário do que alegam os defendentes, a acusação não questiona o mérito da escolha do critério de fixação do preço das ações. A irregularidade identificada pela acusação diz respeito, precisamente, à justificativa apresentada.

40. Pelo exposto, entendo que José Roberto Amoriello, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, conselheiros presentes à reunião ocorrida em 30.12.2008, devem ser responsabilizados pela infração ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76.

II.2. DO CONTRATO DE MÚTUO DE 27.7.2006

41. Como apurado pela SEP, Clarion e Manacá celebraram, em 27.7.2006, contrato de mútuo segundo o qual a Manacá, sempre que dispusesse de capital disponível, deveria depositar, diariamente, determinado montante, definido a seu critério, em conta-corrente compartilhada com a Clarion, a qual, por sua vez, ficava autorizada a sacar segundo a sua necessidade. Em contrapartida, a Clarion deveria pagar à Manacá, mensalmente, o correspondente a 1,8% dos saldos diários dessa conta-corrente. Caso o saldo fosse devedor, caberia então à Manacá pagar juros, na mesma importância.

42. Para a acusação, o contrato teria sujeitado a Companhia ao arbítrio da Manacá, que fazia jus a rentabilidade de 1,8% ao mês sobre o valor que decidisse

unilateralmente depositar na conta conjunta. Além disso, ao comparar a rentabilidade do contrato de mútuo com a taxa correspondente ao custo de capital de terceiro, constante do laudo de avaliação utilizado na aquisição da unidade produtora de álcool situada no município de Ibaiti, verificou-se que essa última seria significativamente inferior. Enquanto o custo de capital de terceiro indicado no laudo correspondia a 13% ao ano, o contrato de mútuo estabelecia remuneração anual de 23,87%.

43. Nos termos do art. 245, *"os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado (...)."*

44. A Exposição de Motivos da Lei esclarece que a norma é destinada a proteger acionistas minoritários e credores da companhia dos prejuízos que poderiam resultar da realização de operações com sociedades integrantes do mesmo grupo econômico¹¹. Cuidando-se de partes relacionadas, sujeitas a controle ou influência significativa comum, avulta o risco de os termos da transação não se revelarem equitativos, já que não foram negociados *arm's length*, como ocorreria entre partes independentes. Daí porque o legislador, no aludido art. 245, enfatiza o dever de lealdade dos administradores, bem como exige deles que ajam com elevada diligência na condução das negociações. Nessa direção, cumpre-lhes adotar todas as medidas a seu alcance para que a transação observe condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado.

45. Desta feita, não se afigura comutativo o negócio firmado fora das condições gerais de mercado ou em termos mais onerosos do que aqueles observados em contratos semelhantes firmados pela companhia com terceiros independentes. Nesse sentido já se observou que¹²:

"[o] fim da lei é evitar que a companhia favoreça, com prejuízo próprio, a controladora ou outra sociedade do grupo. Favorecimento pressupõe obséquio, parcialidade: não há favorecimento enquanto a sociedade contrata aos preços em vigor no mercado ou fixados pelo Estado, ou nas mesmas condições em que estaria disposta a contratar com terceiros".

46. Em que pese o rigor da Lei e a intensidade dos deveres fiduciários impostos aos administradores, entendo que, no presente caso, as provas dos autos não são suficientes para comprovar o desvio de conduta dos administradores na celebração do contrato de mútuo firmado em 27.7.2006 entre a Clarion e a acionista controladora Manacá.

47. Atendo-me aos elementos acostados aos autos, não vejo como concluir que o referido mútuo tenha sido prejudicial aos interesses da Companhia. Diferentemente do sustentado pela acusação, não há provas que demonstrem que o mútuo foi firmado com a finalidade espúria de viabilizar o acréscimo de participação da Manacá no capital social da Companhia.

48. Note-se, a propósito, que o aumento de capital, no qual o crédito resultante do mútuo foi aproveitado, ocorreu aproximadamente quatro anos após a celebração do empréstimo, o que torna, ao menos, incerta a existência, entre os dois atos, da relação teleológica aventada pela acusação.

49. Tampouco se pode afirmar que a remuneração ali pactuada em favor da Manacá era incompatível com as condições gerais de mercado ou com aquelas praticadas pela Companhia em negócios similares. Nesse tocante, a acusação baseia-se em apenas duas evidências: de um lado, o fato de os juros serem devidos à Manacá em razão da mera disponibilização de recursos na conta-corrente, independentemente do efetivo aproveitamento pela Companhia; de outro, a diferença significativa entre a taxa de juros estipulada no mútuo e a taxa de custo de capital de terceiro que consta do laudo de avaliação encomendado pela Companhia, por ocasião da aquisição da unidade produtora de álcool de Ibaiti.

50. No entanto, quanto ao primeiro ponto, cumpre observar que não há prova nos autos de que os recursos disponibilizados pela Manacá na conta-corrente não tenham sido apropriados pela Companhia. Sendo assim, considero, ao menos, plausível de que tenham sido aproveitados e, por consequência, devidamente remunerados pela Companhia.

51. A meu ver, a alegação da acusação de que o mútuo teria submetido a Companhia ao arbítrio da controladora somente seria procedente diante da evidência de que, de fato, os recursos foram depositados na conta corrente em volume superior à necessidade de caixa da Companhia, o que, contudo, não restou comprovado no presente caso.

52. Quanto ao segundo ponto, concordo que a diferença entre a taxa de juros estipulada no mútuo e o custo de capital de terceiro encontrado no laudo de avaliação é significativa. No entanto, como reconhece a própria acusação, é no mínimo duvidosa a credibilidade que se pode conferir ao referido laudo, que, como apurado, foi elaborado por sociedade que desempenhava, entre outras, *"atividades de gravação de som e de edição de música"*.

53. Além disso, é forçoso reconhecer que a taxa de custo de capital de terceiro, estimada por avaliador contratado, não constitui indicação direta e precisa acerca do custo de financiamento do capital de giro da Companhia. Não se pode afirmar, de maneira conclusiva, que a Companhia teria conseguido pagar juros de 13% ao ano, em vez de 23,87%, caso tivesse buscado recursos junto a uma instituição financeira, em vez de celebrar o mútuo com sua controladora.

54. Em suma, pelas razões expostas, entendo que não restou configurada, no presente caso, a infração ao disposto no art. 245 da Lei nº 6.404/76. Desse modo, voto pela absolvição dos diretores Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno da acusação de infração ao referido dispositivo legal. As mesmas razões me levam também a votar pela absolvição de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho da acusação de infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea f, da Lei nº 6.404/76.

55. Nada obstante, julgo importante tecer algumas considerações a respeito da acusação imputada pela SEP ao diretor Paulo César de Moura Bueno. O acusado não assinou o contrato de mútuo e não há, nos autos, qualquer indício de que tenha participado de sua negociação. A acusação baseia-se apenas no fato de que não há registro de sua oposição à realização do negócio e também porque, em resposta a a ofício¹³ da área técnica, teria defendido a comutatividade do mútuo.

56. A meu ver, a conduta do diretor não foi, minimamente, individualizada pela SEP, a quem competia, todavia, apurar a sua participação no suposto ilícito antes de formular a acusação.

II.3. DO ARRENDAMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL OBJETO DO FATO RELEVANTE DE 25.7.2007

57. Conforme apurado pela SEP, em 1.9.2007, a Clarion arrendou à P.A.C. unidade industrial que havia adquirido da Manacá, mediante remuneração de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por mês. O contrato permaneceu em vigor por poucos meses, tendo sido desfeito em 15.2.2008. A área técnica concluiu que a taxa de remuneração do arrendamento corresponderia a apenas 0,51% ao mês, já que a Companhia teria pago R\$ 58.261.000,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil reais) pelo imóvel.

58. Para a acusação, os diretores da Clarion teriam violado tanto o disposto no art. 153 quanto o disposto no art. 154 da Lei nº 6.404/76, uma vez que adquiriram o imóvel sem que houvesse capital de giro disponível para a sua exploração e cederam o seu uso em contrapartida à percepção de remuneração substancialmente inferior aos juros mensais de 1,8% devidos pela Companhia à Manacá, em razão do contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006. Além disso, a SEP levou em consideração que um dos quotistas da P.A.C. é, respectivamente, filho e irmão de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho.

59. A acusação, como se vê, questiona a tomada de decisão negocial por parte dos administradores da Companhia. Para a SEP, os diretores não agiram com diligência e no interesse da Companhia porque (i) as condições financeiras da Clarion não eram apropriadas para a aquisição da unidade industrial e (ii) o seu posterior arrendamento se deu em condições, no juízo da área técnica, prejudiciais.

60. Em casos como o presente, este Colegiado tem se baseado, reiteradamente¹⁴, na *business judgment rule*. Tal orientação, recepcionada do direito norte-americano, visa a evitar que o administrador seja indevidamente responsabilizado em razão de decisão negocial tomada de forma diligente, de boa-fé e no interesse da companhia. Justifica-se na constatação de que não compete ao órgão regulador rever o mérito de decisão negocial e punir aquele que, de forma diligente e bem intencionada, realizou determinada transação que, todavia, acabou por se revelar prejudicial à companhia. Se agisse dessa maneira, o regulador desestimularia a (saudável e indispensável) assunção de riscos pelo administrador e, por conseguinte, geraria entraves à plena consecução do objeto social da companhia.

61. Por essa razão, ao examinar o cumprimento do dever de diligência por parte do administrador, a CVM tem levado em consideração o processo decisório observado, e não o mérito da decisão ou os resultados que dela decorreram.

62. No caso concreto, caberia à área técnica averiguar se, ao decidir por adquirir a mencionada unidade industrial e, posteriormente, arrendá-la, os acusados agiram (i) de forma diligente, procurando reunir e estudar as informações relevantes que razoavelmente se encontravam ao seu alcance; (ii) de boa-fé; e (iii) no que acreditavam ser o melhor interesse da Clarion. No entanto, ao avaliar tão somente as

condições financeiras da Companhia e os termos contratuais da operação, parece-me que a acusação se baseou, exclusivamente, no mérito da decisão dos diretores.

63. A meu ver, isso já seria o suficiente para absolver os administradores. No entanto, acredito que outro ponto relativo à acusação mereça destaque.

64. Conforme consta dos autos (fls. 324-328 e 357-360), o contrato de compra e venda da referida unidade industrial foi assinado pelos diretores José Martins Pereira e Alexandre Bride, ao passo que o contrato de arrendamento encontra-se subscrito somente por José Martins.

65. Paulo César de Moura Bueno não assinou qualquer dos documentos. Isso me leva a crer que Paulo César foi acusado somente porque era diretor da Clarion à época dos fatos. Acredito que o mesmo tenha ocorrido com Alexandre Bride no que diz respeito à responsabilidade pela assinatura do contrato de arrendamento.

66. À semelhança da imputação formulada contra Paulo César relativa ao contrato de mútuo firmado em 27.7.2006, de que cuidei linhas acima, o termo de acusação não cuidou de individualizar a conduta dos diretores em relação à suposta irregularidade ocorrida na negociação do contrato de arrendamento celebrado com a sociedade P.A.C.

67. A meu ver, a acusação também não demonstrou a participação de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho na referida irregularidade. Nesse tocante, ao que tudo indica, o termo de acusação entendeu que ambos deveriam ser responsabilizados por infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, porque seriam parentes de um dos sócios da P.A.C. e beneficiários da operação de aquisição e subsequente arrendamento da unidade industrial.

68. O raciocínio, contudo, não me convence. Em primeiro lugar, porque não há provas objetivas aptas a refutar os argumentos apresentados pelos acusados para justificar que a aquisição da unidade industrial e seu posterior arrendamento tenham sido realizados no melhor interesse da Companhia. Nesse sentido, os acusados aduziram que o arrendamento resultou da falta temporária de capital de giro e não durou mais do que alguns meses, tempo suficiente para o financiamento da atividade a ser desenvolvida na unidade industrial.

69. Em segundo lugar, porque não me parece conclusivo o argumento de que a operação seria prejudicial à Companhia, uma vez que a remuneração obtida com o arrendamento seria expressivamente inferior à taxa de juros devida pela Companhia à Manacá em razão do contrato de mútuo celebrado em 27.7.2006. Nesse tocante, ao contrário da SEP, não identifiquei relação direta entre os negócios, de modo que, a meu ver, a taxa de juros estipulada no referido contrato de mútuo não comprova a falta de comutatividade do arrendamento.

70. Diante de tudo isso, voto pela absolvição de José Martins Pereira, Alexandre Bride e Paulo César de Moura Bueno da acusação de infração ao disposto nos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/76, e de Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, da acusação de violação do disposto no art. 116, parágrafo único, da mesma Lei.

II.4. DO AUMENTO DE CAPITAL DE 28.6.2010

71. O conselho de administração da Clarion deliberou novo aumento do capital social da Companhia em 29.6.2010, quando a cifra aumentou de R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) para R\$ 1.070.000.000,00 (um bilhão e setenta milhões de reais), mediante a integralização de créditos detidos pela Manacá em face da Companhia, decorrentes de contrato de mútuo firmado em 27.7.2006. O preço de emissão foi fixado em R\$ 9,50 por ação, equivalente a um deságio de 9,18% sobre a média de cotação das ações preferenciais emitidas pela Clarion durante o primeiro semestre de 2010.

72. Para a acusação, a descrição da forma de cálculo do preço de emissão não seria suficiente para esclarecer o motivo pelo qual se preferiu a cotação das ações da Clarion em bolsa de valores em vez dos outros critérios de precificação previstos pelo §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, a perspectiva de rentabilidade da Companhia e o valor do patrimônio líquido de suas ações.

73. Por essa razão, no entendimento da SEP, o conselheiro José Roberto Amoriello não teria justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de precificação, em infração ao disposto no §7º do art. 170 da referida lei. Por conta da redefinição jurídica dos fatos por mim proposta e aprovada por este Colegiado em 19.5.2015, os demais conselheiros que deliberaram o aumento de capital, Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, passaram a ser acusados da mesma infração.

74. Assim como a justificativa apresentada para a precificação das ações no âmbito do aumento de capital, ocorrido em 30.12.2008, entendo que aquela apresentada para o aumento de 28.6.2010, ora em exame¹⁵, também não se deu da forma exigida pelo aludido dispositivo legal.

75. Da leitura da respectiva ata, verifico que os conselheiros apenas descreveram o critério escolhido, mas não o justificaram. Nesse sentido, a ata limita-se a informar que foi promovido um deságio de 9,18% sobre a cotação das ações preferenciais em determinado período e que esse deságio tinha por objetivo criar atratividade à subscrição das ações. Não há, assim, como depreender as razões pelas quais se decidiu utilizar a cotação das ações para precificar aquelas a serem emitidas.

76. A defesa de José Roberto Amoriello repetiu os argumentos apresentados em relação à acusação de falta de justificativa pormenorizada por ocasião do aumento de capital de 30.12.2008. Em face desses argumentos, reitero as razões já expostas.

77. Além disso, ressalto que o fato de as ações terem sido negociadas em número suficiente ou não para permitir a utilização da cotação como critério de precificação, questão bastante explorada pelas defesas, não tem relevância para o presente processo. Não se questiona, aqui, se a escolha do critério foi adequada ou não, mas se a justificativa de utilização desse critério foi devidamente pormenorizada na ata da reunião do conselho de administração.

78. Pelo mesmo motivo, refuto os argumentos apresentados pela defesa conjunta de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, no sentido de que o preço foi definido com base nos melhores interesses dos acionistas e da própria Clarion.

79. Assim sendo, voto pela condenação de José Roberto Amorielo, Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari por infração ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76.

II.5. DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUA NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DE 2011

80. Por fim, Alexandre Bride é acusado de, na qualidade de diretor de relações com investidores da Clarion à época dos fatos, não ter divulgado as informações relativas aos contratos de mútuo celebrados em 27.7.2006 e 30.12.2008. Nesse sentido, a acusação apurou que o Formulário de Referência de 2011, versão 3.0, não contemplava nenhum dos dados exigidos pelo item 16 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009, relativo a transações com partes relacionadas.

81. De fato, não consta do referido Formulário qualquer informação a respeito dos contratos de mútuo celebrados com partes relacionadas. Essa informação só veio a ser inserida na versão 4.0 do Formulário de Referência de 2011, encaminhado à CVM em 25.11.2011.

82. Em sua defesa, o acusado alegou que a disponibilização dessas informações se deu tempestivamente, uma vez que a exigência para apresentação das informações aludidas no item 16 do Anexo 24 somente foi realizada por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 228/11, de 18.10.2011 (fl. 434).

83. Não concordo com esse entendimento. A obrigação de incluir a aludida informação no Formulário de Referência não tem por fonte o ofício enviado pela área técnica, mas a norma geral e abstrata contida no art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009¹⁶. Em definitivo, o acusado deveria ter incluído os contratos de mútuo no Formulário de Referência no prazo e na forma estabelecidos na Instrução CVM nº 480/2009, e não após o recebimento do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº 228/11.

84. O fato de o acusado ter suprido a irregularidade tão logo tenha sido intimado pela SEP não afasta a ocorrência do ilícito nem o exime de responsabilidade, embora, a meu ver, mereça ser levado em consideração na fixação da penalidade correspondente.

85. Não concordo com a alegação da defesa de que, em razão do disposto no art. 58 da Instrução CVM nº 480/2009¹⁷, aplicar-se-ia, ao caso concreto, o procedimento previsto para a aplicação de multa cominatória, conforme as regras da Instrução CVM nº 452/2007, devendo o presente processo administrativo sancionador ser arquivado.

86. Isso porque o presente caso não trata de descumprimento de prazo previsto para a entrega de informações periódicas, ao qual seria aplicável o regime estabelecido na mencionada instrução normativa. Trata, em vez disso, da falta de inclusão de informações sobre os já referidos contratos de mútuo na seção do Formulário de Referência da Companhia, referente às transações entre partes relacionadas.

87. Diante dessas considerações, voto pela condenação de Alexandre Bride por violação ao art. 13 combinado com o art. 45, ambos da Instrução CVM nº 480/2009.

III. CONCLUSÕES

88. Passo, enfim, às conclusões do voto.

89. A conduta dos conselheiros José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, em relação ao aumento de capital da Clarion ocorrido em 30.12.2008, mostra-se especialmente reprovável. Como já exposto, eles foram responsáveis pela aprovação, no âmbito do conselho de administração, dos atos contratuais simulados e fraudulentos destinados a elidir a incidência da norma imperativa do art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76, que deveria ter sido observada por ocasião da realização do aumento de capital da Companhia com bens da sociedade controladora Manacá. Ao agirem dessa maneira, permitiram que a referida integralização fosse efetuada, tomando por base laudo de avaliação que, contrariamente à prescrição legal, não foi submetido ao crivo da assembleia geral de acionistas, na qual, diga-se por oportuno, a Manacá estaria impedida de votar, haja vista o disposto no art. 115, §1º, da Lei.

90. Dessa manobra fraudulenta resultou o abalo, em prejuízo dos credores, da realidade do capital social e a expressiva diluição da participação dos acionistas minoritários (da ordem de 1.429%).

91. Voto, portanto, com base no inciso II e §1º, inciso I, do art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela condenação dos acusados José Roberto Amorielo, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite à penalidade pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um, por infração ao disposto no art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/1976.

92. Pelas mesmas razões acima expostas, a conduta de Reno Ferrari Filho parece-me especialmente reprovável. Na qualidade de acionista controlador indireto da Companhia e titular, por intermédio da sociedade estrangeira G.I.C., de 99,5% do capital social da Manacá, Reno Ferrari Filho foi o principal beneficiário da operação fraudulenta, que, como visto, permitiu à Manacá integralizar ações da Companhia com ativos sem a observância das prescrições legais que visam preservar a realidade do capital social.

93. Desse modo, a Manacá conseguiu integralizar ações de emissão da Companhia no valor total de R\$ 631.268.500,00 (seiscentos e trinta e um milhões, duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) mediante o aporte de ativos cuja avaliação não foi aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, contrariamente ao que determina o art. 170, §3º, combinado com o art. 8º da Lei nº 6.404/1976.

94. Diante disso, com base no inciso II e §1º, inciso II, do art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto pela condenação de Reno Ferrari Filho, pela infração ao disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, à penalidade pecuniária no montante de R\$ 157.817.125,00 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e dezessete mil e cento e vinte e cinco reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação irregular de integralização de ações.

95. Acredito que a fixação de penalidade em montante inferior ao limite de 50% (cinquenta por cento) previsto em lei se mostra adequada e proporcional no presente caso, tendo em vista a dispersão acionária relativamente baixa da Companhia à época dos fatos¹⁸.

96. Ainda em relação ao aumento de capital de 30.12.2008, voto, com base no inciso I do art. 11 da Lei nº 6.385/76 e em consideração aos precedentes desta Autarquia¹⁹, pela condenação de José Roberto Amoriello, José Martins Pereira e Oriel Campos Leite, na qualidade de membros do conselho de administração da Clarion, à penalidade de advertência, por não terem justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão, em violação ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

97. Quanto ao aumento de capital realizado em 28.6.2010, voto com base no inciso I do art. 11 da Lei nº 6.385/76 e em linha com os precedentes já mencionados, pela condenação de Reno Ferrari e Regina Martin Ferrari, na qualidade de membros do conselho de administração da Clarion, à penalidade de advertência, por não terem justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão no aumento deliberado em 28.6.2010, em violação ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

98. No entanto, em relação a José Roberto Amoriello, que também participou da aprovação desse aumento de capital, entendo que não se justificaria a aplicação de nova penalidade de advertência, uma vez que ele já tinha cometido a mesma infração por ocasião do aumento de capital deliberado em 30.12.2008. Assim, voto, com base no inciso II e §1º, inciso I, do art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela aplicação da penalidade pecuniária no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por não ter justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério de fixação do preço de emissão no aumento deliberado em 28.6.2010, em violação ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76.

99. Quanto ao descumprimento do disposto no art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009, ressalto que Alexandre Bride, na qualidade de diretor de relações com investidores, deixou de prestar no formulário de referência informações relevantes acerca de contratos de mútuo celebrados entre a Clarion e a acionista controladora Manacá. Cuidando-se de transações entre partes relacionadas, integrantes do mesmo grupo econômico, a sua divulgação ao mercado mostra-se importante e a sua omissão, por conseguinte, deve conduzir à aplicação de penalidade proporcional, apta a desestimular condutas semelhantes.

100. De outra parte, parece-me necessário levar em consideração, na definição da penalidade, o fato de o acusado ter sanado as omissões no formulário de referência tão logo tenha sido intimado pela SEP. Também considero importante levar em conta que as falhas informacionais ocorreram ainda na fase inicial da vigência da Instrução CVM nº 480/2009, que introduziu o Formulário de Referência na regulamentação do mercado de valores mobiliários.

101. Diante disso, voto, com base no inciso I do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de Alexandre Bride à penalidade de advertência, pela infração ao disposto no art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009.

102. Enfim, pelas razões já indicadas, voto pela absolvição de:

- (i) Reno Ferrari, da imputação de infração ao preceituado pelo art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, em relação ao aumento de capital da Clarion ocorrido em 30.12.2008;

(ii) Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno, na qualidade de diretores da Clarion, da imputação de violação ao previsto no art. 245, e Reno Ferrari e Reno Ferrari Filho, da acusação de infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea f, da Lei nº 6.404/1976, por conta da assinatura do contrato de mútuo de 27.7.2006 em bases supostamente não equitativas; e

(iii) Alexandre Bride, José Martins Pereira e Paulo César de Moura Bueno, na qualidade de diretores da Clarion, da imputação de violação ao disposto nos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/1976, no que se refere à aquisição pela Companhia e posterior arrendamento da unidade industrial objeto do fato relevante de 25.7.2007.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ "Art. 1º - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."

² "Art. 2º - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...)"

³ "Art. 2º - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital".

⁴ Veja-se nessa linha: "(...) não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender o contrário significaria uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição intercorrente" (PAS CVM nº 22/94, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, jul. 15.4.204).

⁵ A simulação, tal como a fraude à lei, pode ser empregada com o fim de afastar a incidência de determinada norma jurídica, cuja observância não interessa às partes. Ocorre que, na fraude à lei, as partes desejam efetivamente que o negócio produza seus efeitos, por meio dos quais pretendem alcançar resultado prático equivalente ao proibido pela norma imperativa fraudada. Já o negócio simulado não é seriamente desejado pelas partes, que lançam mão do expediente apenas para ocultar a real situação jurídica existente. Ou seja, procuram encobrir a violação da lei sob a prática (aparente) do ato. V. nesse sentido Regis Fichtner Pereira, *A Fraude à Lei*, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, pp. 47-55. Sob a vigência do Código Civil de 1916, a diferenciação entre a fraude à lei e simulação despertava intenso debate, e não eram poucos os autores que, a despeito das críticas, admitiam a figura híbrida da *simulação em fraude à lei*. A questão se revestia de notável interesse prático, vez que permitia a expansão do regime da nulidade, aplicável à fraude, à simulação, que, a princípio, configurava hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, submetida a prazo prescricional exíguo. No entanto, com o advento do Código Civil de 2002, a discussão perdeu, em grande medida, relevância, haja vista a opção legislativa de tratar tanto a fraude como a simulação como causas de nulidade do negócio (art. 166, inciso VI, e art. 167).

⁶ Regis Fichtner Pereira, *A Fraude à Lei*, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, pp. 22-23. E assim arremata o autor: "para que se detecte a ocorrência de fraude à lei, importante se torna a investigação do resultado alcançado pelo agente ao praticar o ato jurídico, a fim de se saber se ocorreu, em verdade, a violação indireta da norma, perpetrada através de atos aparentemente lícitos; uma vez que, para atingir determinado resultado, o fraudador se utiliza, por vezes, de atos que a lei permite ou simplesmente não proíbe, surgindo a consequência de restar inaplicável a norma, apesar de os efeitos do ato praticado serem os mesmos que a lei fraudada visa a afastar" (p. 26).

⁷ Ebert Vianna Chamoun, *A Fraude à Lei no Direito Romano*, Tese de concurso para provimento da cadeira de Direito Romano da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1955, p. 11, *apud* Regis Fichtner Pereira, *A Fraude à Lei*, Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 24.

⁸ “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.” Nesse sentido, ao discorrer sobre o contrato de mútuo, Caio Mário da Silva Pereira afirma que “[d]entro da nossa sistemática, (...) mantida pelo Código Civil de 2002, a entrega efetiva da coisa é requisito de constituição da relação contratual (Instituições de Direito Civil. vol. III. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p 295).

⁹ O trecho da ata a respeito da escolha do critério de precificação das ações é o seguinte: “O preço de emissão das ações foi fixado com observância do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76 e parecer de orientação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de números 1/78 e 5/79, prevalecendo o critério do Valor Patrimonial das Ações, que em 30.09.2008 é de R\$ 26,42, tendo em vista que apesar do registro de seus títulos para negociação em Bolsa, ainda não houve negociação. O objetivo da presente emissão é a ampliação das atividades da companhia, contemplando seu objeto social, com o reforço do capital de giro e a redução do endividamento da companhia” (fls. 07 e 08).

¹⁰ “A disposição do §7º do art. 170 da lei não é apenas de caráter informacional. Ela contém, também, um elemento relevante de prestação de contas e responsabilização (accountability e liability), destinando-se reforçar o comprometimento dos administradores com os critérios escolhidos e propostos à assembleia, bem como sua eventual responsabilização no caso de falha em seus deveres de diligência e probidade.” (Processo CVM nº RJ2004/5476, voto do Presidente Marcelo Trindade, julg. 1.3.2005)

¹¹ Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério da Fazenda.

¹² José Luiz Bulhões Pedreira, *Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas*, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (Org.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1941. V. também Nelson Eizirik, *A Lei das S/A Comentada*, vol. 3, Quartier Latin, 2011. pp. 359 e 360; e Modesto Carvalhosa, *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*, 2ª edição, vol.4, tomo II, São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 32 e 33.

¹³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº226/11, de 18.10.2011 (fl. 429).

¹⁴ Cf. PAS CVM nº RJ2005/1443, Rel. Dir. Pedro Marcilio de Souza, julg. em 10.5.2006, e PAS CVM nº RJ2008/9574, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julg. em 27.11.2012.

¹⁵ A justificativa, constante da reunião do conselho de administração da Clarion, ocorrida em 28.6.2010, se deu nos seguintes termos: “O critério utilizado para o cálculo do preço de emissão foi a média dos últimos 6 meses (04.01.10 a 10.06.10), no qual o preço encontrado foi de R\$ 10,46 para as ações preferenciais. Vale destacar que as ações ordinárias da companhia não foram cotadas até o presente momento. Cabe ressaltar que a companhia decidiu promover um deságio de 9,18% sobre a média dos últimos 6 meses para as ações preferenciais, o que nos fez chegar ao preço de R\$ 9,50. No caso das ações ordinárias (que não apresentaram até o presente momento nenhuma cotação), o preço estipulado terá como base o mesmo preço utilizado para as ações preferenciais. É importante salientar que o deságio proposto pela companhia tem como objetivo, exclusivamente, criar uma atratividade adicional para que os atuais acionistas subscrevam sua participação proporcional ao aumento de capital.”

¹⁶ “Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.”

¹⁷ “Art. 58. Nos termos das normas específicas a respeito do assunto, o emissor está sujeito à multa diária em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução para entrega de informações periódicas, no valor de: I – R\$500,00 (quinhentos reais) para os emissores registrados na categoria A; e II – R\$300,00 (trezentos reais) para os emissores registrados na categoria B.”

¹⁸ De acordo com informações do Formulário IAN da Companhia referente à data-base de 31.12.2007 (antes da diluição provocada pelo aumento de capital realizado em 30.12.2008), 5% das ações emitidas pela Companhia se encontravam em circulação. Tais informações estão disponíveis na página da CVM na rede mundial de computadores.

¹⁹ Veja-se: (i) PAS CVM nº RJ2009/8316, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 9.4.2013; (ii) PAS CVM nº RJ2012/7767, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 2.4.2013; e (iii) PAS CVM nº RJ2010/1737, julg. em 19.10.2010.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/11073 realizada no dia 15 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/11073 realizada no dia 15 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e também pela aplicação das penalidades de advertências e multas, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento